

moniales, un jefe que rige como señor absoluto la vida social y económica de su grupo. La sucesión debe entonces de haber sido en su status de jefatura y no respecto de la propiedad de bienes, pues éstos estaban asignados, en el pensamiento social, al grupo familiar.

II. Desglosándose de su poder soberano sobre éste y al compás de cambios socioeconómicos ese poder gerencial del *pater* sobre el patrimonio familiar habríase convertido en propiedad privada individual, con exclusión de los demás miembros del grupo. Su capacidad de designación de heredero por testamento debe de haberse entonces "patrimonializado", es decir, adquirido un predominante carácter de libre disposición de los bienes patrimoniales, tanto en favor de herederos que adquiriesen *per universitatem* el patrimonio o partes alicuotas de él, como en favor de legatarios que sucedieran a título particular en determinadas cosas o derechos desgajados de la masa patrimonial.

III. Esa absoluta libertad de disponer, en un creciente clima de individualismo y relajación de los fuertes y austeros lazos de solidaridad grupal, llevó a la necesidad de prevenir abusos y omisiones. Así, tanto la jurisprudencia como la legislación establecieron pautas de limitación cuya expresión más trascendente habría de ser la institución de la legítima.

IV. Una paralela evolución lleva en el sistema de la sucesión intestada a ir institucionalizando en cambios jurídicos la transformación de la familia, que pasa de una estructuración de amplio grupo de apretada vida social, económica y política bajo la común dependencia de un jefe —el *paterfamilias*—, a lo que podríamos llamar familia individualista, basada en los afectos, en una íntima convivencia y en un ambiente de economía de intercambio y diversificación. En el régimen sucesorio se reconoce relevancia jurídica a la cognación*, al principio en forma subsidiaria o complementaria de la agnación*, pero luego en detrimento de la predominancia de ésta.

V. Una última trascendente evolución es la que lleva a la simplificación formal de los testamentos y a la complementación de éstos por *codicilos* y *fideicomisos*, orientados a agilizar y facilitar el ejercicio de disposiciones de última voluntad.

SUCESION UNIVERSAL MORTIS CAUSA

Tanto la testamentaria cuanto la *intestata* fueron regladas por dos sistemas: el de la *hereditas*, del *ius civile*, y el de la *bonorum possessio*; establecido por el pretor.

HEREDITAS

Esta palabra ha sido usada en dos diferentes sentidos, referidos ambos a la sucesión de un sujeto, el heredero (*heres*), en las relaciones jurídicas titularizadas por otro sujeto en el momento de su muerte. Este último se designa con la expresión *de cuius*, proveniente de la frase "*de cuius hereditate agitur*" ("de la herencia del cual se trata").

(A) En el primer sentido, el significado *hereditas* indica un complejo unitario (*universitas*) de *corpora* (cosas corporales) y *iura* (derechos), complejo considerado como un todo único destinado a ser adquirido, en un solo acto y por una sola causa, por un heredero.

(B) En el segundo sentido, *hereditas* equivale al *ius hereditatis* (derecho a la herencia), es decir, la titularidad de la herencia, el derecho del *heres* a suceder al *de cuius*.

- En los primeros tiempos el título de *heres* habría correspondido tan sólo al descendiente o *suus* (suyo) del *paterfamilias*. Así la ley de las XII tablas, cuando se trata de agnados no *sui*, no dice que serán herederos, sino que tomarán el patrimonio (*familia*).
- Contrariamente a las sucesiones universales *inter vivos*, la *hereditas* comprendía los pasivos patrimoniales, pudiendo resultar que las deudas superasen al activo; es decir, que fueran *ultra vires hereditatis* (más allá de las fuerzas de la herencia): resultaría así una *hereditas damnosa* (herencia dañosa, perjudicial).
- Pero no todas las relaciones jurídicas inherentes al *de cuius* se transfieren con la adquisición de la *hereditas*. Además de las que derivan de situaciones o condiciones personales —de padre, de tutor, de marido—, deben también excluirse algunas patrimoniales, como las resultantes del usufructo, uso, habitación, mandato, sociedad, locación de obra y de servicios; la *actio iniuriarum*; los privilegios como el del *beneficium competentiae*, etcétera.
- Tampoco quedaban incluidas las responsabilidades por acciones penales, salvo en la medida de lo que se hubiera podido enriquecer el heredero por los delitos cometidos por el *de cuius*.

102

504

1

101

- Tampoco la posesión pasa al heredero, pero éste puede, si entra él en posesión de la cosa y con *animus possidendi*, computar para sí el tiempo de posesión del *de cuius* y así completar el período necesario para una *usucapio* iniciada por este último.

La normativa de la *hereditas* es del *ius civile*, resultante de la ley de las XII tablas y de otras leyes, de la interpretación de los prudentes, de los senadoconsultos y, por último, de las constituciones imperiales.

En cambio, se deberá al *imperium* y a la *iurisdictio* del pretor la formación de un sistema paralelo al de la *hereditas*, auxiliar y suplementario al principio, prevaleciente después: el de las *bonorum possessiones*.

BONORUM POSSESSIO

Otro modo —además del de la sucesión en la *hereditas* en virtud de la condición de *heres*— de realizar una persona la adquisición del patrimonio —o cuota parte de éste— de un difunto fue la concesión de la *bonorum possessio*, otorgada por el pretor a pedido de parte y previo sumario o especial —según la hipótesis estuviera o no prevista en el edicto— examen de la solicitud.

- En el primer caso se llamaba *bonorum possessio edictalis* y en el segundo *decretalis*, por ser necesario un específico *decretum*.

I. Objeto de la *bonorum possessio* —al igual que el de la *hereditas*— era la universalidad de cosas y derechos del *de cuius*, en la que unitariamente y por el sólo acto de la concesión pretoriana, sucedía el *bonorum possessor*, que de no surgir quien tuviere un mejor título de sucesión llegaría, con el transcurso del tiempo, a usucapir las cosas —*usucapio hereditatis*— y, con el ejercicio de *actiones utiles*, a realizar los derechos personales. Es decir, a conseguir una titularidad, de acuerdo al *ius civile*, de todos los derechos reales y personales que había investido el *de cuius*.

- De allí que si bien sólo el *ius civile*, y no el pretor, podía hacer *heres* a alguien, aquel a quien el pretor otorgaba la *bonorum possessio* llegaba a ser considerado *loco heredis* (en lugar del heredero).

e. II. La *bonorum possessio* surgió dentro del derecho suce-

sorio como institución meramente posesoria; fue atribuida tanto (A) como posesión provisional de los bienes hereditarios mientras se desarrollaba un proceso de petición de herencia, como (B) en favor de aquellos que, justificando prima facie una pretensión a la herencia —fuese testamentaria o *ab intestato*—, solicitaban ser puestos en la posesión de los bienes hereditarios sin necesidad del más complicado procedimiento de una *hereditatis petitio**.

- Quien resultaba, entonces, por concesión del pretor, *bonorum possessor*, tenía a su disposición el interdicto *quorum bonorum* contra los poseedores o detentadores de bienes hereditarios.
- Estos, o cumplían con la orden del pretor y el *bonorum possessor* quedaba con la posesión de los bienes en cuestión, o no obedecían, y tenía lugar, entonces, el proceso formulario consecuente. Si el *bonorum possessor* no podía en ese proceso exhibir un título válido para la *hereditas*, el anterior poseedor quedaba con la posesión.
- Triunfante, en cambio, el *bonorum possessor*, y puesto en posesión de los bienes, esto no impedía que sucumbiera eventualmente en un posterior proceso frente a quien exhibiera un título sucesorio mejor.

La *bonorum possessio* tenía, pues, un carácter subordinado y auxiliar del sistema de la *hereditas*; resultaba entonces sin efectividad sustantiva —*sine re*—, pues quien la había obtenido estaba destinado a sucumbir frente a quien hiciera valer un mejor título de acuerdo con el *ius civile*.

III. Empezó siendo, pues, una institución confirmatoria o coadyuvatoria del *ius civile*. Pero esto evolucionará en dos sentidos: (A) se comenzará a dar la *bonorum possessio* no sólo a los que invocaban ser herederos de acuerdo con el *ius civile*, sino también a otras personas; (B) en muchos supuestos se la otorgó *cum re*, es decir, con criterio prevaleciente sobre lo dispuesto por el *ius civile*. La *bonorum possessio* resultó, entonces, *ampliatoria* y *correctora*, respectivamente, del *ius civile*.

(A) 1) El pretor acostumbró a conceder la *bonorum possessio* a personas instituidas como herederas por cierto acto testamentario no válido según el *ius civile* —testamento pretorio*. Se trataba de una *bonorum possessio secundum tabulas* (de acuerdo con las tablillas [en las que estaba escrito el testamento]).

2) En los casos en que el *de cuius* había muerto intestado, el pretor llegó a conceder la *bonorum possessio* a personas unidas al *de cuius* por cognación, vínculo no contemplado hasta la época por el *ius civile*. Se trataba entonces de una *bonorum possessio sine tabulis* (sin tablillas).

3) Por último se concedió la *bonorum possessio*, aun existiendo testamento, a personas no instituidas por el *de cuius*. En esos casos se hablaba de una *bonorum possessio contra tabulas* (contra las tablillas).

(B) Si tenemos en cuenta que el *bonorum possessor* se convertía en propietario *ex iure quiritium* a través de la *usucapio*, es decir, de acuerdo al *ius civile*, y que a través de las *actiones utiles* concedidas por el pretor llegaba a realizar en su favor los derechos de crédito del *de cuius*, resultaba que, sin alcanzar la categoría de *heres* —que sólo podía ser conferida por testamento o normativa del *ius civile*—, llegaba al mismo resultado práctico que el *heres*: suceder al *de cuius* en todos sus derechos reales y personales.

Resultaron, pues, dos sistemas: el del *ius civile*, que determinaba la calidad de heredero, y el pretoriano, que concedía la *bonorum possessio*. La concurrencia de estos dos sistemas llevó a la necesidad de ir articulando un orden de preferencia entre los herederos del *ius civile* y los *possessores* del derecho pretoriano.

Si el pretor concedía la *bonorum possessio* a una persona no contemplada por el *ius civile* o ubicada en éste en un segundo término, había que resolver en cada hipótesis si el heredero civil podía actuar exitosamente contra el *bonorum possessor* por medio de una *hereditatis petitio*. La doctrina hablaba de *bonorum possessio sine re* o *cum re*, según que el titular de ella debiera ceder su posesión o mantenerla ante la pretensión del heredero civil. Así, por ejemplo, un rescripto de Antonino Pío concedió al *bonorum possessor secundum tabulas* —testamento pretoriano— el rechazar con una *exceptio doli* la *hereditatis petitio* de los herederos civiles *ab intestato*: esa *bonorum possessio* resultaba, así, *cum re*.

El pretor, pues, según las distintas hipótesis, pudo sostener a ciertos *bonorum possessores* ante la pretensión civilmente válida de ciertos herederos, denegándoles acción a éstos o concediéndoles excepciones a aquéllos.

IV. Al confundirse en la época posclásica el *ius civile* con el *ius praetorium* u *honorarium*, al convertirse las *actiones utiles* en simplemente directas, al unificarse la propiedad bonitaria con la quiritaria, la distinción entre *bonorum possessio* y *hereditas* perdió contenido substancial y sólo subsistió en la terminología y formalidades del procedimiento.

• Lo que sí se conservó fue la primitiva utilización de la *bonorum possessio* como institución posesoria coadyuvadora de la herencia, en tanto atribuía a quien invocaba un derecho de sucesión no necesariamente óptimo una mera posesión que duraba en tanto no se presentara un titular de un mejor derecho sucesorio.

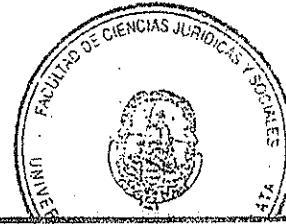
DELACION DE LA HERENCIA

Para que alguien pueda ser llamado *heres* —heredero— o *bonorum possessor* —poseedor del patrimonio hereditario— es necesario que exista alguna causa de delación en virtud de la cual la misma le sea “deferida” —*deferre hereditatem*— o por la cual sea “llamado” —*vocare ad hereditatem*.

I. La delación de la herencia se puede hacer ya *ex testamento* —herencia testamentaria—, ya por la ley, —herencia *ab intestato*.

II. En primer término, ocurrida la muerte de una persona, hay que dar predominio a la herencia testamentaria. Si no llegara a haber testamento —o éste fuese inválido o ineficaz— correspondería abrir la herencia *ab intestato*.

III. Algo que ya hemos visto es que no puede ocurrir que ambas herencias puedan presentarse en forma simultánea, ya



103

504 1

102

que "*nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*" ("nadie puede morir en parte testado y en parte intestado").

- * Este principio sufre algunas excepciones, tales como el caso del testamento militar y de otros supuestos —que serán estudiados más adelante— de reclamo de la herencia de los herederos *ab intestato* contra los instituidos en el testamento.

ADQUISICION DE LA HERENCIA

Los herederos pueden ser suyos y necesarios (*sui et necessarii*), necesarios (*necessarii*) y extraños o voluntarios (*extranei aut voluntarii*).

Podemos también agruparlos en *domestici heredes*, que serían los dos primeros casos, y *extranei heredes*, o sea el último, para remarcar que los primeros corresponden al ámbito familiar y los últimos están al margen de dicho ámbito.

HEREDEROS SUYOS Y NECESARIOS

Son tales los descendientes del *pater* que se encontrasen o se hubieran encontrado sometidos a su *patria potestas*.

- * Son, por tanto, "herederos suyos y necesarios":
 - (A) Los hijos sometidos a la *patria potestas*, fuesen éstos legítimos, adoptivos o legitimados.
 - (B) Los nietos sometidos en forma directa a la *patria potestas*; es decir por haber desaparecido el respectivo padre, o sea el *filius* del causante.
 - (C) Los póstumos que nacieren después de la muerte del causante, y que de no haber sido por este hecho hubieran estado bajo su *patria potestas*.
 - (D) La *uxor in manu*, que se encuentra en el lugar de hija (*loco filiae*) y también la nuera *in manu*, en caso de haber muerto su marido.
- En cambio, están excluidos los hijos emancipados de la *patria potestas*.

I. Estos herederos adquieren la herencia en forma automática —*ipso iure*— con la muerte del causante.

- * Significa esto que no necesitan de ningún acto de aceptación de la herencia. Según Gayo, son los llamados *sui* por ser *domestici heredes*, y estando vivo el *pater*, en cierto modo están considerados como propietarios, y son llamados *necessarii* porque en todos los casos, ya sea por testamento, ya por *ab intestato*, se hacen herederos, lo quieran o no.

II. Sin embargo, el pretor, también por razón de equidad, les concederá el *ius abstinendi*, de tal modo que los herederos que recibieran una herencia muy cargada de deudas —y con el fin de no responder por ellas— pudieran evitarla.

Para abstenerse (*se abstinere*) bastaba con que no hubieran realizado acto alguno relativo a la herencia, o sea, no haberse inmiscuido en la misma (*se immiscere*).

- * Sin embargo, debido a que la sucesión se opera *ipso iure*, no pierden la calidad de herederos, sino que simplemente están "abstenidos" de la misma, con lo cual evitan las consecuencias infamantes de la *bonorum venditio*.
- * Por ello, las manumisiones otorgadas en el testamento son válidas, ya que hay institución de heredero. El heredero puede arrepentirse de su abstención antes de que se hubieran vendido los bienes —*bonorum venditio*—. En la época de Justiniano se les otorgará un plazo de tres años, siempre y cuando no hubiera ocurrido la venta en el lapso intermedio.

HEREDERO NECESARIO

Se denomina heredero necesario al esclavo del testador instituido heredero por éste en el mismo momento que le otorgaba la manumisión.

El propósito consistía en que quien tuviere dudas acerca de su solvencia, con el fin de evitar los efectos infamantes de la *bonorum venditio* que pudieran llevar contra él sus acreedores luego de su muerte, instituya heredero al esclavo que manumitía para que los efectos de la ejecución recayesen sobre éste.

- * Para la existencia del *heres necessarius* eran precisos tres requisitos: a) que la *heredis institutio* estuviese acompañada por la manumisión expresa —aunque Justiniano la entendió no necesaria, ya que tácitamente había existido manumisión; b) que el esclavo perteneciera al testador *ex iure Quiritium*, tanto en el momento de hacerse el testamento cuando en el del deceso, y c) que el esclavo fuese el único heredero.
- * Sin embargo, el pretor —también por razón de equidad— le otorgará el beneficio de conservar para sí los bienes adquiridos por él después de la muerte del patrono, de tal modo que si bien tiene que responder con los bienes hereditarios, aun cuando no alcancen a cubrir las deudas, por regla general no responderá con estos suyos procedentes de adquisiciones ulteriores.

- * Se trataría en este caso de una verdadera *separatio bonorum* (separación de los patrimonios), concedida para evitar la confusión total de ambos patrimonios: el constituido por la herencia del causante y el adquirido por el propio liberto con posterioridad al hecho.

HEREDEROS VOLUNTARIOS O EXTRAÑOS

Se entiende por tales aquellos otros herederos que por ser extraños a la familia del causante son instituidos por éste en el testamento, por lo que, para adquirir la herencia —dado que no están obligados a ello—, deberán expresar su aceptación en forma voluntaria.

I. En un comienzo bastaba la realización de algún acto no formal que demostrara inequívocamente la voluntad de aceptación. Esta forma se denominaba *pro herede gestio* (actuación como heredero), como en el caso de cultivar un campo perteneciente a la herencia, o arrendarlo, o venderlo.

II. Posteriormente —lo que después constituirá la forma típica de la época clásica— comenzó a usarse una forma ritual denominada *cretio* (decisión [por la herencia]), que se establecía con las palabras: "Puesto que P. Mevio me ha instituido heredero en su testamento, yo decido aceptar la herencia".

- * Mediante esta forma se pretendía que el heredero se decidiera de una manera expresa, evitando dilaciones. Generalmente iba acompañada de un plazo, por lo común de cien días, para que el heredero pudiera reflexionar antes de tomar su decisión. Así, por ejemplo: "Que Ticio sea mi heredero. Y que hagas la *cretio* dentro de los cien días siguientes a aquel en que tengas conocimiento y puedas practicarla; si no la hicieras, sé desheredado".
- * Al respecto existían dos formas de establecer esta cláusula. El ejemplo dado encierra una *cretio vulgaris*, la cual, al decir "a aquel en que tengas conocimiento", está tratando de evitar que el plazo corra inútilmente para alguien que haya ignorado el haber sido instituido heredero. Cuando faltan dichas palabras, la *cretio* es llamada de "plazo cierto" (*cretio certorum dierum*). En ésta los días se cuentan cronológicamente desde la muerte del causante, y para la *lex Papia Poppaea*, desde la apertura del testamento.
- * La *cretio* puede también ser "perfecta" cuando la falta de aceptación aparece sancionada por la desheredación; o "imperfecta", cuando falta dicha cláusula. Para este último caso podría usarse la *pro herede gestio*.

III. En el derecho posclásico la *cretio* caerá en desuso y fi-

nalmente será abolida por Justiniano. La forma empleada fue la *aditio hereditatis* (aceptación de la herencia), que consistía en una declaración expresa, pero no solemne.

- * Este vocablo expresa bien gráficamente el sentido del acto jurídico, puesto que *ad-ire* significa "ir hacia", con lo que se explicita que algo debe hacer el heredero para que consiga realmente la herencia. Frente a esta manera expresa, continuará manteniéndose la tática de la *pro herede gestio*.

IV. Conforme con el *ius civile*, no hay plazo para aceptar la herencia, a menos que en una *cretio perfecta* se lo hubiere señalado. Como esto podía dar lugar a dificultades para los acreedores que no tuviesen posibilidad de demandar sus créditos, el pretor les permitirá realizar una intimación al heredero para que declare si es heredero (*interrogatio an heres sit*). El intimado podía obtener un plazo —*spatium deliberandi*— para pensar qué debía hacer.

- * Si no contestaba en ese plazo —como ya dijimos de cien días—, se lo tenía por no heredero y se podía realizar la *bonorum venditio*.
- * Justiniano establecerá el plazo máximo en nueve meses —si fuere concedido por el juez— o en un año —si fuere concedido por el emperador—; pero si el heredero no contestaba antes del vencimiento del plazo, se lo tenía como heredero aceptado.

De todos modos, siempre se admitió que el heredero voluntario o extraño pudiera manifestar su voluntad, expresa o tática de no aceptación de la herencia. Se habló, entonces, de *repudiatio*: una vez repudiada una herencia, no cabía una aceptación posterior.

RELACIONES JURIDICAS QUE SURGEN DE LA HERENCIA NO ADQUIRIDA

HERENCIA YACENTE

Cuando la herencia aún no ha sido aceptada por el heredero —que es el caso del heredero voluntario—, hay un lapso en el cual la herencia, por no ser del causante ni del heredero, parece no ser de nadie.

404

504 1

103

(A) En un comienzo los romanos hablaron de la misma como de una *res nullius* o *sine domino*.

- * Siendo así, quien se apoderase de una cosa de tal herencia no cometía *furtum*. Y si bien éste es el principio general, en la época clásica se dan equitativas excepciones. Así, se comete tal delito si la cosa es poseída por un heredero o por un tercero que posee a cuenta de la herencia.
- * Marco Aurelio creará la figura delictiva del *crimen expilatae hereditatis* (crimen de despojo de la herencia).
- * Incluso, el mismo pretor nombrará un *curator* para cuidar de los bienes en beneficio de los acreedores.

(B) Si bien en la época clásica se continuó la configuración antigua, se comenzó a hablar de la *hereditas iacens* como de un patrimonio temporariamente sin sujeto.

Para poder solucionar los inconvenientes prácticos nacidos de la continuación de los créditos y las obligaciones, se recurría ya al criterio de referir tanto los beneficios como los perjuicios a la persona del heredero, ya a la persona del causante. Tanto uno como otro serán, en el interin, sustituidos por la *hereditas*.

(C) Se ha llegado por ello, interpretando la expresión comúnmente usada de que "la *hereditas* cumple las veces de la persona" ("*hereditas personae vice fungitur*"), a pensar que la *hereditas iacens* era una persona jurídica. Pero tal pensamiento no aparece del todo claro ni aun en los compiladores justinianeos.

USUCAPIO PRO HEREDE

(A) Mientras no apareciese un heredero —y siempre que no sucediesen las hipótesis de *furtum* vistas en el caso anterior—, se permitía que cualquiera entrara en posesión de la herencia a los efectos de usucapirla.

- * Esta *usucapio pro herede* va a ser calificada por Gayo de *lucrativa* y de *improba*, ya que éste la admite incluso respecto del poseedor de mala fe, exceptuando de este modo el principio de la *usucapio* que exige la *bona fides*.
- * Los motivos que se daban eran uno de índole económica: permitir a los acreedores tener a alguien con quien pleitear para cobrar sus créditos; y otro de índole religiosa: cuando el usucapiente continuaba la memoria de la religión familiar del difunto —*sacra privata*.

- * El plazo de la *usucapio* era el de un año, ya que como el objeto era la *hereditas*, no entraba en la categoría de "inmuebles", sino en la de "las otras cosas" (*ceterarum rerum*) de las XII tablas.

(B) Si aparecía un heredero, podía reclamar la herencia siempre y cuando no hubiese transcurrido el plazo de la *usucapio*; en caso contrario, la posición del usucapiente era inmovible.

(C) Pero desde los comienzos de la época clásica se consideró que lo usucapido no debía ser la *hereditas*, sino las cosas hereditarias en forma particular.

- * Un senadoconsulto de Adriano permitirá la *usucapio pro herede* sólo en el supuesto de que el usucapiente fuera de buena fe, es decir, creyera ser heredero. En efecto, concedió al verdadero heredero obtener la revocación de la *usucapio* del poseedor de mala fe.

IN IURE CESSIO HEREDITATIS

I. Los llamados *ab intestato* que no sean *sui* o *necessarii* pueden ceder su lugar en la herencia que les corresponde mediante una *in iure cessio*.

Los herederos testamentarios no pueden ceder sus derechos antes de la aceptación, teniendo en cuenta la voluntad del testador que los puso en forma personal en tal lugar. Una cesión semejante es nula.

II. En cambio, luego de aceptarla, es decir, después de entrar efectivamente en posesión de la herencia, los testamentarios y también los *sui* y *necessarii* podían ceder sus derechos por una *in iure cessio*.

- * La situación en estos casos era muy particular. Se entendía que las cosas eran transmitidas al adquirente. En cambio, los créditos hereditarios se extinguían por renuncia implícita, en tanto que las deudas quedaban siempre en cabeza del heredero cedente.
- * La *in iure cessio hereditatis* desaparecerá aproximadamente en el siglo III d.C., al igual que la forma genérica de la *in iure cessio*.
- * Un caso distinto al que aquí tratamos es el de la "compraventa de una herencia ya adquirida". Se solía usar la *mancipatio* rigiéndose por las reglas genéricas de la compraventa.
- * En este supuesto, a los efectos de poder ejercitar las acciones en favor y en contra de la herencia, se celebraban las *emptae et venditae stipulationes*, por las cuales el adquirente podía ejercitar las acciones en pro de la herencia adquirida y se hacía cargo de los efectos de aquellas dirigidas contra ella.

EFECTOS DE LA HERENCIA

COMUNIDAD HEREDITARIA

Entre todos los herederos surge un estado de comunidad, en virtud del cual cada uno participará, en su parte alícuota, de las cosas, de los créditos y de las deudas.

- En el derecho antiguo esta comunidad —*consortium*— era una forma muy particular, denominada *erctum non citum* (heredad no dividida), en la que, más que lo patrimonial, interesaba el estado jurídico-familiar de sus componentes.
- Más adelante será un estado de hecho, que se regirá como un *quasi-ex-contratto*, semejante a la sociedad.
- La forma de poner fin a la comunidad hereditaria es mediante el ejercicio de la *actio familiae erciscundae*.

ACRECIMIENTO

En el caso de existir varios herederos —ya testamentarios, ya *ab intestato*— podía suceder que alguno de ellos no quisiera o no pudiera ser heredero. En ese supuesto, de manera automática, *ipso iure*, la porción que le correspondía pasaba a acrecer (*adscrescere*) la porción del otro o de los otros herederos.

El fundamento del *ius adcrendi* reside en la vocación que —ya fuese por la ley, ya por la voluntad del testador— los herederos tienen de la *hereditas* considerada *in solidum*, por lo que el vacío dejado por alguno debe ser llenado por otro u otros.

(A) En el caso de tratarse de herederos *ab intestato*, si uno no podía o no llegaba a ser heredero, su porción era repartida entre los demás, agregándose a las suyas propias.

- Nótese, sin embargo, el caso del hijo que concurría con los dos nietos habidos de un hermano premuerto. Si no llegaba a ser heredero uno

de los dos nietos, el acrecimiento beneficiaba a su hermano, pues ambos concurrían en representación del hijo premuerto, y no al tío.

(B) En el caso de la herencia testamentaria se pueden dar varios supuestos.

1) Si se deja a un solo heredero no toda la herencia, sino sólo parte de ella, se entiende que éste acrece por el todo, porque de lo contrario se estaría violando el principio de que "no se puede morir en parte testado y en parte intestado".

2) Si hay varios herederos respecto del todo, la norma será el acrecimiento; de tal modo que si no se ha hecho ninguna especificación corresponde que se haga entre todos los coherederos en forma proporcional a la cuota de cada uno de ellos. Pero puede ocurrir que en la institución de herederos se hayan realizado agrupamientos (*coniunctiones*) de entre algunos de ellos, por lo cual el acrecimiento se realizará sólo entre los herederos conjuntos.

- El modelo de este procedimiento sería el siguiente: "Que Ticio sea heredero de la mitad de la herencia; que Mevio y Seio sean herederos de la otra mitad". En este supuesto, si Seio no llega a ser heredero, el acrecentamiento se producirá para Mevio —unido por la misma *coniunctio*— y no para Ticio.

3) Hay que recordar que conforme con las leyes caducarias —*lex Iulia de maritandis ordinibus* y *lex Iulia et Papia Pappaea*—, la parte que debían recibir los *caelibes* (célibes) y la mitad de la que debían recibir los *orbi* (casados sin hijos) se volvía *caduca* e iba a parar finalmente al fisco.

- En realidad, estas leyes admitían un *ius capiendi* (permisión de tomar [esa *pars caduca*]) para los herederos *liberos habentes* (que tienen hijos) y, en su ausencia, para los legatarios *liberos habentes*, que asumirían un rol de herederos, y, finalmente, al fisco.

COLACION DE BIENES

La colación (*collatio [bonorum]*) es la obligación que tienen en la sucesión *ab intestato* aquellos descendientes que, ya por ser emancipados y contar por esta razón con un patrimonio propio, ya por otras causas, hubieran recibido favorecimientos

105

504 1

106

del causante de denunciar dichos bienes y aportarlos al patrimonio en el que suceden al *de cuius*.

- El propósito evidente de esta institución es asegurar la igualdad de todos los herederos *ab intestato*.
- El primer caso que ocurre es el de los emancipados que piden la *bonorum possessio* de la herencia de su padre, bien por el llamamiento edictal *unde liberi*, bien *contra tabulas*. Sucedió acá que mientras los *sui heredes* habían quedado sometidos a la *patria potestas* colaborando en la formación del patrimonio, el emancipado —por ser *sui iuris*— tenía oportunidad de formar su propio patrimonio, resultando injusto que lo conservase y al mismo tiempo participase del patrimonio familiar. Por ello debía "colacionar" sus bienes, incrementando el patrimonio hereditario.
- Cuando el emancipado se presenta al pretor, éste le concede la *bonorum possessio* si aporta su patrimonio, dándolo o prometiéndolo a cada uno de los *sui heredes* mediante una *stipulatio*, o mediante una garantía (*cautio*) de hacerlo.
- El patrimonio del emancipado es considerado en forma total, salvo en aquellos rubros —como el *peculio castrense**— que aun siendo *sui heres* no hubieran engrosado el patrimonio del *pater*.
- Cada emancipado debía colacionar por su cuenta, formándose en cada caso las proporciones de cuotas entre los *sui heredes* y dicho emancipado.
- Por evidente analogía, el pretor admitirá la *collatio dotis* (colación de la dote). Acontecía que si un *pater* había constituido una dote en favor de su hija —*alieni iuris* o emancipada—, ésta estaría en situación privilegiada respecto de sus hermanos, ya que de disolverse su matrimonio por muerte o por divorcio, la dote regresaba exclusivamente a ella.
- De manera similar al caso anterior, el pretor obligará mediante una *stipulatio* a la hija que pide la *bonorum possessio* a la colación de esa dote para compartirla con sus hermanos, siempre, por supuesto, de acuerdo con las respectivas cuotas de la herencia.
- A partir de Antonino Pio, la mujer —aunque no pida la *bonorum possessio*— está obligada a colacionar la dote, siempre que sea heredera por el *ius civile*.
- El emperador Gordiano la obligará a colacionar en favor de sus hermanos *sui heredes* como también de los emancipados, con lo cual se inicia el proceso de generalización de la *collatio bonorum*.

En la última época del Derecho Romano se determinará la generalización de la obligación de colacionar para los descendientes.

Así, por una constitución del 472 d.C., los descendientes —sucesores *ab intestato* o *bonorum possessores contra tabulas**— estaban obligados a colacionar lo recibido a título de

dote o donación matrimonial en favor de los otros descendientes, estuviesen éstos emancipados o no.

Justiniano extenderá la obligación de colacionar respecto de toda adquisición que pueda ser entendida como un adelanto de la herencia en favor de uno de los descendientes, especialmente en el caso de las donaciones ordinarias.

Esta *collatio descendantium* configura, en forma genérica, la idea de un igual tratamiento hereditario —sin preferencias extratestamentarias— en favor de todos los descendientes.

RESPONSABILIDAD POR LAS DEUDAS

Una vez operada la sucesión, la regla general es que, al unirse el patrimonio hereditario con el del heredero, ambos pasan a formar uno solo, confundándose los créditos y las deudas hereditarias con los del heredero.

I. Los acreedores del causante se unen con los acreedores del heredero, encontrándose, en principio, en un pie de igualdad para demandar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

Mientras el patrimonio del heredero fuera suficiente y no estuviera cargado de deudas, no se presentaba ningún problema. Pero los acreedores del causante corrían el riesgo de encontrarse con un heredero cargado de deudas —*heres suspectus*— y no lograr así el cobro de sus créditos.

II. Por ello, el pretor concederá a esos acreedores del causante el beneficio de la *separatio bonorum* (separación de patrimonios), de tal modo que se entiende como no reunido el patrimonio del causante con el del heredero, y, al estar separados, podrán demandar sus créditos sobre los bienes hereditarios sin intromisión de los acreedores del heredero.

* Sólo pueden pedir la *separatio bonorum* los acreedores del causante, no los del heredero.

- * Sin recurrir a la *separatio bonorum*, los acreedores del causante podían exigir al *heres suspectus* la prestación de fianza que asegurasen el pago de los créditos. A esto se lo denominó la *satisfactio suspecti heredis*. De no acceder, se podía llegar a la *bonorum venditio* del patrimonio del heredero.

III. El heredero responde de las deudas hereditarias no sólo con los bienes de la herencia, sino con los suyos propios. Se habla entonces de una responsabilidad *ultra vires hereditatis* (más allá del monto de la herencia).

Acá se presenta un caso inverso al anterior, en tanto el heredero corría el riesgo de recibir una *hereditas damnosa* (herencia perjudicial), es decir, cargada de deudas.

- * El heredero *suus et necessarius* tenía el remedio del *ius abstinendi*, lo mismo que el testamentario el recurso de no aceptar la herencia. Pero muchas veces el heredero, con el fin de preservar la memoria del causante y no dejarle la marca infamante de deudas impagas —con la consecución de la *bonorum venditio*—, lo mismo aceptaba la herencia.
- * Cuando el contenido netamente económico signe la transmisión hereditaria, el problema variará y se adoptarán otras medidas.

IV. Justiniano, para proteger al heredero contra una *hereditas damnosa* por la cantidad de deudas del causante, le otorgará a aquél el *beneficium inventarii* (beneficio de inventario), que significaba la limitación de la responsabilidad a los bienes del activo hereditario. Se habla entonces de una responsabilidad *intra vires hereditatis* (dentro de las posibilidades de la herencia).

- * Para tener el *beneficium inventarii*, el heredero, dentro de los treinta días —computados desde la apertura del testamento o desde que éste se enteró de la delación de la herencia—, debe comenzar un inventario de los bienes del causante.
- * Este inventario es realizado ante un *tabularius* (escribano) con citación de los legatarios, fideicomisarios y acreedores, que de estar ausentes se los reemplazaba por tres testigos. El plazo de realización de dicho inventario era de sesenta días. El heredero lo deberá suscribir firmando y declarando no haber realizado ninguna ocultación dolosa.
- * El heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario irá luego pagando a los acreedores del causante a medida que aquéllos se vayan presentando y hasta agotar los bienes dejados en la herencia.

PROTECCION DEL DERECHO HEREDITARIO

HEREDITATIS PETITIO

Quando el heredero, conforme al *ius civile*, ve desconocida su situación de tal, puede ejercer contra aquel que pretende ocupar su lugar en los bienes hereditarios una *actio in rem* denominada *hereditatis petitio*.

- * Esta *actio in rem* funciona de manera muy semejante a la *rei vindicatio*. La diferencia esencial reside en que esta última se debe ejercer para declarar que es propietario y por ende recobrar la posesión de una *res corporalis*; en cambio, la *hereditatis petitio* es para lograr la declaración de que es heredero, y en consecuencia le sea atribuida la *hereditas* como *universitas iuris*.

(A) Esta acción puede ser ejercida por quien se considere que es un heredero civil —por lo que debe probar su vocación hereditaria— contra:

- 1) quien afirme ser heredero —*pro herede*—, planteándose en consecuencia el problema de titularidad entre ambos;
- 2) quien esté poseyendo cosas hereditarias —*pro possessore*— sin alegar título alguno y esperando producir la *usucapio pro herede* *;
- 3) el que hubiere simulado que estaba poseyendo cosas de la herencia —*possessor fictus*— y que responde, en este caso, por los daños y perjuicios ocasionados;
- 4) quien hubiere cesado dolosamente en la posesión de las cosas hereditarias por haberlas vendido.

(B) Si el demandado se niega a ser parte y en consecuencia no se puede entablar la *hereditatis petitio*, el pretor concede al actor el *interdictum quam hereditatem*, por el cual el poseedor debe restituir las cosas hereditarias.

(C) Por ser una *actio arbitraria* *, el juez tiene amplias facultades respecto de lo que le debe ser restituido al actor victorioso.

106

504 1

103

(D) Los efectos principales de la *hereditatis petitio* serían los siguientes:

1) el poseedor vencido debe reintegrar la totalidad de las cosas hereditarias, fueren del *dominium ex iure Quiritium*, fueren por haberlas tenido el causante *in bonis*, ya se tratase de un comodato, de un *pignus*, etcétera;

2) se debían devolver también los frutos que se hubieran percibido y se poseyeran en el momento de la *litis contestatio*; si se trataba de un poseedor de mala fe, debía devolver incluso los que hubiera dejado de percibir por no actuar diligentemente.

* En cuanto a las mejoras necesarias y útiles hechas por el poseedor, éste las puede recobrar negándose a reintegrar las cosas mediante una *exceptio doli* *.

3) Si el demandado, con anterioridad a la *litis contestatio* ha vendido una cosa hereditaria, si era poseedor de mala fe se hacía responsable del menor precio que se hubiese obtenido de la cosa, con lo que debía reponer el valor total de la venta y daños acaecidos; si era poseedor de buena fe, debía devolver el precio obtenido con la venta, o por el que se hubiera enriquecido;

4) si se trataba de créditos ya cobrados, en principio el deudor no quedaba liberado, pero el heredero victorioso podía hacerse devolver los importes obtenidos por el vencido, aprobando las prestaciones realizadas.

(E) El heredero por el *ius civile*, en lugar de ejercer la *hereditatis petitio*, podía también ejercitar separadamente las acciones particulares o singulares, como reclamar un crédito hereditario o reivindicar el dominio de una cosa.

* Para estos casos el demandado tuvo en su beneficio una *praescriptio* *, que luego se transformó en una *exceptio quod praeiudicium hereditati non fiat* (que no haya prejuzgamiento para la herencia), con el fin de que no resultara prejuzgado en relación con la herencia. El juez debía juzgar el caso concreto sin entrar a considerar para nada la cuestión sucesoria. En tanto se mantuvo como *praescriptio*, fue uno de los muy raros casos de esa parte de la fórmula concedida en beneficio del demandado.

INTERDICTUM QUORUM BONORUM

Este interdicto *adipiscendae possessionis* (para adquirir la posesión) era otorgado a quien le correspondía la *bonorum possessio* con el fin de entrar efectivamente en posesión de la herencia.

A su vez, tenía el *interdictum quod legatorum* para recobrar la cosa de manos de quien la retuviese pretendiéndose legatario.

* Al *bonorum possessor*, para que pudiera ejercitar las acciones en favor y en contra de la herencia le eran concedidas por el pretor *actiones ficticiae* sobre la ficción de que fuera el heredero.

SUCESION TESTAMENTARIA

La herencia testamentaria tiene precedencia respecto de la herencia *ab intestato*, lo cual significa que muerta una persona lo primero que corresponde averiguar es ver si ha dejado expresada su voluntad en un testamento. De no ser así, o de haberse dejado testamento pero ser éste nulo o no existir herederos, entonces corresponde abrir la herencia *ab intestato*.

CONCEPTO DE TESTAMENTO

El testamento es un acto solemne de última voluntad por medio del cual se instituye heredero. Puede contener otras cláusulas —manumisiones, legados, dación de tutor—, pero, en principio, la eficacia de las mismas dependerá de la existencia de la institución de heredero (*heredis institutio*), de la cual Gayo dice bien claramente, resaltando su importancia, que es *caput et fundamentum testamenti* (cabeza y fundamento del testamento).

* Es por ello que las definiciones de Ulpiano— "Testamento es la declaración, de acuerdo a derecho, de nuestra intención, hecha de manera solemne, para que valga después de nuestra muerte"— y de Modestino— "Testamento es la expresión, de acuerdo a derecho, de nuestra vo-

luntad respecto de lo que se quiere que se haga después de nuestra muerte"—, no obstante ser las dos únicas que surgen de los textos, no serían del todo exactas debido a que olvidan acentuar la existencia de la institución de heredero.

- Pero el mismo Ulpiano nos señala la importancia de este requisito —que distinga al testamento romano del vigente en otros pueblos antiguos— al decir en otro párrafo que con tres palabras se puede hacer testamento: "Lucio sea heredero" ("*Lucius heres esto*").

FORMAS DE TESTAMENTO

Testamentum calatis comitiis - Testamentum in procinctu. — Las fuentes hablan del primer tipo de testamento conocido: el que se celebraba ante las curias * en los comicios convocados (*calatis comitiis*) dos veces por año —24 de marzo y 24 de mayo— y presididos por el pontífice máximo. Su sucedáneo en tiempos de apremio bélico era el llamado *in procinctu* (en disposición de batalla), celebrado ante la formación militar. En ambos casos el *paterfamilias* habría enunciado su disposición de última voluntad ante sus conciudadanos, testigos (*testes*) entonces del *testamentum*.

(A) Pero, ¿sobre qué habría versado esa declaración de última voluntad? Desde los juristas romanos hasta el presente hubo una interpretación que extendía hasta esas instituciones el carácter patrimonialista que tomaron y tienen los actos de última voluntad. Según esa interpretación, pues, en aquel *testamentum* el *pater* habría nombrado uno o varios herederos —fueran o no de su grupo familiar— que lo sucederían en el total de sus derechos subjetivos patrimoniales, tal como puede hacerlo hoy en día cualquier persona, por lo menos en los límites de una cierta porción garantida a ciertos herederos *ab intestato* denominada legítima *.

(B) En cambio, interpretaciones recientes —basadas en las modalidades de la sociedad arcaica en lo que respecta al carácter político de la organización de la familia y el familiar de la propiedad, a lo prevaleciente de las situaciones y relaciones de status y poder (*mancipium*) sobre las patrimoniales— concuerdan en el carácter político y no patrimonial de aquel *testamentum*: se trataría de la designación primitiva de un ver-

dadero sucesor en la jefatura del grupo familiar y no en la masa patrimonial. Esto explicaría la solemnidad y el interés público de esa expresión de voluntad: la comunidad toma cuenta de la continuidad de una de sus células primordiales.

Esas interpretaciones presentan dos líneas principales:

1) Una de ellas considera que ese *testamentum* es propio —y necesario— del tipo de familia grande o agnaticia; el *pater* debe elegir de entre todos los sometidos a su patria potestad a un único varón púber para que sea *heres*, el futuro *pater*. Cuando se produzca la transición al tipo de familia *proprio iure* —cada una encabezada por cada uno de los *filiifamilias* que con la muerte del *pater* han devenido *sui iuris*—, el *heres* designado no sería ya, como antes, un único *pater* de una única familia agnaticia, sino que tendría a su cargo una de las resultantes familias *proprio iure*, pero conservando una cierta ascendencia moral de liderazgo sobre los otros flamantes *patres*, junto con el derecho a eventuales tutelas y curatelas sobre los miembros de la primitiva familia, con la atención de los cultos familiares —*sacra*— y, tal vez, con una parte especial —núcleo— del patrimonio: el *heredium*.

2) La otra interpretación entiende que el *testamentum* ya se refiere al sistema de la familia *proprio iure*: cuando existen *filiifamilias* varones púberes está asegurada la continuidad familiar a través de una o más familias —según el número de aquellos que serían automáticamente, de acuerdo con los principios de la sucesión intestada, *heredes sui*—; sólo si no hay varones púberes en su familia, el *pater* debe designar, previa incorporación al grupo por adopción, a un extraño. El *testamentum* que estamos tratando sería entonces una especie de adrogación * con expresa finalidad de asegurar un jefe que continúe la familia.

En ambas interpretaciones el *heres* habría tenido la absoluta disposición del patrimonio familiar como jefe o gerente del grupo y no como sucesor individual de derechos patrimoniales privados.

107

504 1

106

Testamentum per aes et libram. — En cambio, el primer tipo de testamento de índole patrimonial habría sido la *mancipatio familiae*, con el ritual de los actos *per aes et libram* (por el cobre y la balanza).

(A) En un primer momento se permitía que quien se encontrara en peligro de muerte hiciera ante otro —generalmente un amigo de aquél— una *mancipatio* de todo su patrimonio —*mancipatio familiae*—, de tal modo que quien la adquiriera —*familiae emptor*— por un acto de buena fe —*fiducia*— se comprometiera a distribuir los bienes conforme con las instrucciones del testador.

(B) En un segundo momento, e interpretándose ampliamente el valor asignado por la ley de las XII tablas a la declaración —*nuncupatio*— en los actos *per aes et libram*, se construirá una forma más típica de testamento. Si bien en éste continuará figurando el *familiae emptor* para que el acto sea válido, el aspecto central será ahora la *heredis institutio*.

* Según nos lo narra Gayo, el procedimiento se llevaba a cabo del siguiente modo: en presencia de cinco testigos y del *libripens*, y después de haberse escrito las tablas del testamento, el testador, por mera formalidad, mancipaba a un tercero —*familiae emptor*— su patrimonio. Este decía entonces: "Yo me encargo por mandato tuyo de custodiar tu familia y tu fortuna, y a fin de que puedas en derecho hacer tu testamento de acuerdo con la ley pública, sean por mí compradas por esta moneda de cobre y por esta balanza de bronce", golpeando luego con el as la balanza y dándole al testador, como forma figurada de pago, esa única moneda (*nummo uno*). El testador, a su vez, teniendo las tablas del testamento, expresaba: "De acuerdo con lo que está escrito en estas tablas y en esta cera, yo doy, lego y testó, y por lo tanto vosotros, Quirites, dadme testimonio de ello".

* El testamento podía también ser oral. Pero de todos modos, el más seguro era el que se realizaba por escrito, en cuyo caso las denominadas tablas de cera eran cerradas con una cinta que llevaba impresos siete sellos: los de los cinco testigos, el del *libripens* y el del *familiae emptor*. La ventaja de este testamento escrito residía, además, en que no se conocían las cláusulas. Luego, al abrirse, debían romperse los sellos.

Testamentum praetorium. — Más adelante, el pretor considerará que la realización de la *mancipatio* podía ser obviada. Por ello determinará en su edicto que concederá la posesión *per*

ditaria —*bonorum possessio*— a todo aquel que le presente su nombre escrito en las tablas del testamento selladas por siete testigos sin preocuparse de la probanza de las formalidades de la *mancipatio*. Esta *bonorum possessio* será *secundum tabulas* * (según las tablillas).

* De este modo, pues, durante la época clásica va a funcionar un testamento civil —con las formalidades de la *mancipatio*— que otorga la *hereditas* y un testamento pretoriano en virtud del cual se otorga la *bonorum possessio*.

Testamentum per scripturam. — En la época posclásica, las dos formas de testar se van aproximando entre sí. Por una disposición de Teodosio II y Valentiniano III (año 439 d.C.) se determinó que el testamento debía ser presentado —abierto o cerrado— ante siete testigos, cada uno de los cuales no sólo debía poner su sello —*signum*—, sino también ser nombrados como tales en el texto —*superscriptio*— y luego firmarlo al pie —*subscriptio*—. Igualmente se habría pedido la *subscriptio* del testador, que de negarse o no poder hacerlo, debía agregarse un octavo testigo.

* Por una constitución posterior de dichos emperadores —año 446 d.C.— se determinó que si el testamento era *holografa manu* (por mano que lo ha escrito todo), es decir, escrito por el testador de su propia mano, no eran necesarios los testigos.

* Esta disposición del año 446 no fue recepcionada por Justiniano; pero, sin embargo, se la aplicó en la *lex romana Burgundionum* *.

* Se admitió también un testamento oral —*nuncupativo*— que estaba reglado desde la constitución del año 439 d.C. Por este testamento se debía hacer conocer la voluntad del testador a los siete testigos, quienes, una vez muerto aquél, debían a su vez dar a conocer dicha voluntad. Tal procedimiento resultaba más inseguro que el que se expresaba en las tablillas, por las dificultades propias que se engendraban al no quedar nada por escrito.

Testamentum tripertitum. — Justiniano, tomando como base la constitución del 439 d.C., establecerá las bases del *testamentum tripertitum*, llamado así porque sus reglas emanan de tres derechos distintos. Así, se ha tomado del *ius civile* la unidad de acto —propia de la *mancipatio*—; del *ius honorarium*, el número de los siete testigos y los sellos, y de las constituciones imperiales, las firmas de los testigos y del testador.

Testamentos especiales. — Hay ciertos testamentos que por razones singulares se apartan de algunas de las formalidades ya explicadas.

(A) En el testamento de los soldados (*testamentum militum*), éstos, como decía Gayo, lo hacen "como quieran o como puedan", quedando dispensados del cumplimiento de las formalidades ya descriptas y libres, por lo demás, de ciertas normas sustantivas.

- Esta ventaja concedida a la *imperitia* y *simplicitas* de los soldados fue dada primeramente por Julio César —aunque sólo por un tiempo determinado—; luego la continuaron los emperadores Tito, Domiciano y Nerva, y, finalmente —por mandato a los gobernadores de provincias—, Trajano.
- Admitido por Justiniano, no se lo extenderá sino a las personas en servicio, no otorgándose a quienes estuvieren de licencia en sus hogares ni tampoco a los veteranos.
- El requisito esencial era que no existiera duda alguna acerca de la institución de heredero. Pero al margen de esta circunstancia, no estaban sujetos al principio de que "nadie puede morir en parte testado y en parte intestado"; podía haber varios testamentos válidos y legar en ellos más de lo indicado por la *lex Falcidia*; no se admitía contra tal tipo de testamento la *querela inofficiosi testamenti*.

(B) En los testamentos celebrados en tiempos de epidemia —*testamentum pestis tempore*— se dispensaba el requisito de la unidad de acto, pudiéndose reunir los testigos en forma separada y en momentos distintos.

(C) En los testamentos celebrados en zonas rurales (*testamentum ruri*), por la dificultad de encontrar testigos se exigían solamente cinco. Y si uno o varios no sabían escribir, bastaba que los otros firmaran por ellos.

(D) Si el testador era ciego o no sabía escribir podía —desde la época del emperador Justino— dictar su testamento en forma oral. Más tarde pudo también testar por escrito utilizando un octavo testigo que supiera escribir o dictándose a un escribano (*tabularius*).

(E) Si el testamento era otorgado en favor de la Iglesia o de instituciones pías, podían obviarse algunas formalidades e, incluso, prescindir de ellas, en favor de la validez de las disposiciones testamentarias.

(F) Por una disposición de Constantino —acogida por Teodosio II y por Justiniano— se determinó que si un *pater* hacía disposiciones en favor de sus hijos y descendientes llamados a heredar *ab intestato*, aunque no fuera formalmente un testamento, podía valer como tal —*testamentum parentis inter liberos*— mientras no contuviera alguna disposición en favor de tercero.

APERTURA DEL TESTAMENTO

Está reglamentada a partir de la *lex Iulia de vicesima hereditatum* (época de Augusto), la cual estableció un impuesto del 5 por ciento sobre las herencias.

El testamento, que generalmente se confiaba a un amigo o se depositaba en un templo, era abierto ante el pretor y en presencia de los responsables del cobro del impuesto y de los testigos que lo habían sellado. A estos últimos se les inquiría sobre si reconocían como propios los sellos, luego de lo cual el testamento era abierto y leído. Los interesados podían examinarlo, dándoseles ocasión para que sacasen copias de él. Finalmente, era sellado y archivado.

CODICILOS

Codicillus (diminutivo de *codex* *) es una disposición de última voluntad, hecha de manera informal, por medio de la cual el causante ruega a otra persona —generalmente al heredero instituido— que cumpla un determinado deseo.

- En un principio, sólo tuvieron fuerza moral de cumplimiento. Pero fue Lucio Léntulo —el mismo que había introducido los fideicomisos— quien provocó una nueva situación cuando, en Africa, ya próximo a morir, escribió codicilos en algunos de los cuales rogaba al propio Augusto que hiciese ciertas cosas por fideicomiso. El César siguió estas recomendaciones y los demás continuaron su ejemplo. Tanto fue así, que la propia hija de Léntulo pagó legados a los cuales no estaba obligada por derecho estricto.
- Interesado en la cuestión, Augusto requirió la opinión del jurista Trebacio, quien los consideró muy útiles y necesarios para los ciudadanos

108

504 1

107

que "a causa de las grandes y prolongadas peregrinaciones que hacían entonces, durante las cuales, si había imposibilidad de hacer un testamento —por ejemplo, por las formas—, al menos podrían hacerse codicilos". Luego, habiendo hecho codicilos el mismo Labeón —jefe de la escuela proculeyana, no afecta a la política de Octavio—, ya nadie dudó acerca de la relevancia jurídica de aquéllos.

I. Podían darse dos clases de codicilos.

(A) Codicilos confirmados por testamento, que eran aquellos previstos en un testamento anterior o confirmados por uno posterior. Se los consideraba como parte integrante del testamento, de cuya validez dependían.

Podían contener todo tipo de disposiciones, legados, manumisiones, etcétera, salvo institución de herederos o desheredaciones. Esta —aparte de las formas exigidas— era la gran diferencia que los separaba de los testamentos.

(B) Codicilos no confirmados en testamento o *ab intestato*. Si bien estaban admitidos, se entendió que por medio de ellos sólo se podían hacer fideicomisos —ya universales, ya particulares— o revocaciones de los mismos.

II. En cuanto a las formas, desde un comienzo el codicilo no estuvo sujeto a ninguna exigencia. Pero desde la época de Constantino, y más tarde en la de Teodosio —coincidente con una cierta aproximación entre testamento y codicilo—, comenzó a requerirse la formalidad testamentaria de siete testigos.

Justiniano estableció —diferenciando nuevamente ambos negocios *mortis causa*— que para el codicilo era necesario solamente la presencia de cinco testigos.

Se acostumbró igualmente a establecer en el testamento la cláusula codiciliar, por la cual, si el testamento, por alguna causa, carecía de valor como tal, de todos modos pudiera seguir teniendo efectos como codicilo. Por esta razón se lo entendía como un fideicomiso —las instituciones de heredero como fideicomiso universal, los legados en fideicomisos particulares y las manumisiones directas en fideicomisarias.

Incluso, en la época justiniana se llegó a considerar que aquella cláusula quedaba sobreentendida cuando no estaba expresamente.

CAPACIDAD DE TESTAR Y CAPACIDAD DE SER INSTITUIDO POR TESTAMENTO

Los romanos empleaban la expresión *testamenti factio* para referirse a la capacidad de otorgar testamento, de intervenir como testigo, de ser heredero o legatario o de obtener cualquier favorecimiento por disposición testamentaria, como, por ejemplo, una designación como tutor.

Se suele distinguir entre *testamenti factio activa* —cuando nos referimos al testador— y *testamenti factio passiva* —cuando nos referimos a los testigos, herederos, legatarios, etcétera.

Testamenti factio activa. — La regla general es que la persona que quiera disponer por testamento debe estar en posesión de los tres *status*: ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Además, debe gozar de la capacidad de hecho para poder hacerlo.

* Hay, sin embargo, excepciones: el *servus publicus* (esclavo público que puede disponer hasta la mitad de su peculio, y los *filiifamilias* que pueden disponer por testamento hasta el monto de su *peculium castrense* y *quasi castrense*.

* Por faltarles capacidad de hecho, no pueden hacer testamento (A) los impúberes; (B) el *furiosus* —salvo en sus intervalos lúcidos— y el *mente captus*; (C) el pródigo; (D) en la primera época, los que padecieran de total mudez o de sordera, por no poder expresar, los primeros, las palabras solemnes correspondientes al acto, y los segundos, por estar incapacitados para escucharlas. Posteriormente, Justiniano permitirá como válidos los testamentos efectuados por ciertas personas, letrados y eruditos, aun cuando hubieran perdido el habla o la condición de oír; (E) tal cual lo dijimos antes, el ciego pudo hacerlo a partir de Justino.

* En principio, las mujeres no podían testar; pero sí podían hacerlo cuando, estando sometidas a la tutela de su sexo, lograban liberarse mediante una *coemptio fiduciaria*. A partir de un senadoconsulto de Adriano podrán hacerlo con la *auctoritas* del tutor. Cuando desaparece la *tutela mulierum*, las mujeres quedarán en libertad de testar.

* En cuanto a la facultad de manumitir por testamento, que la *lex Aelia Sentia* establecía en la edad de 20 años para producir los efectos allí señalados, Justiniano la reducirá a los 18 años cumplidos.

- Referente al requisito de ser ciudadano romano, quedarán exentos los latinos *veteres* y los *coloniarii*; no, en cambio, los *iuniani*.
- El peregrino puede hacer testamento conforme a su *ius civile*; pero tal derecho no se le reconoce, en cambio, al peregrino *dediticio*.

La *testamenti factio activa* se debe tener tanto en el momento de la *factio* del testamento como en el de la muerte del testador.

- Si el testador cayese prisionero del enemigo, el testamento no perdía validez si aquél volvía a Roma —*ius postliminii*—; o si moría prisionero del enemigo —*factio legis Corneliae*.

Testamenti factio passiva. — En principio la posee el que tiene los tres *status*. Pero se pueden dar varios supuestos.

(A) Así, los *fili* y los esclavos pueden ser instituidos herederos o legatarios, pero lo que logren pasa al patrimonio del *pater*. La aceptación tiene que ser hecha por autorización del *pater* o del *dominus*, respectivamente.

El esclavo puede adquirir del dueño por testamento, si al mismo tiempo es manumitido en el mismo testamento.

(B) En cuanto a los *latini iuniani*, si bien tendrían esta facultad, la parte que les perteneciese se volvía *caduca* e iba a parar al fisco, a menos que adquiriesen la ciudadanía en el plazo de aceptación de la herencia (*cretio*).

(C) En cuanto a las *personas inciertas* (*incertae personae*), es decir, aquellas no claramente instituidas, como ser las que resultasen de una situación como la siguiente: "Que sea mi heredero el primero en venir a rendirme las honras fúnebres", no podían ser herederos.

- Entraban en la categoría de *incertae personae* los hijos póstumos —los que nacen después de la muerte del causante—. Pero, desde el principio se reconoció la *testamenti factio passiva* a los *postumi* del causante, quedando la inhabilitación para los *postumi alieni* —hijos póstumos de terceros— que pudieron, sin embargo, adquirir la *bonorum possessio secundum tabulas*. Y más adelante, en la época de Justiniano, no se establecieron distinciones y se los admitió como herederos.
- En un principio entraron también los municipios y corporaciones, si bien luego de una lenta evolución se les admitió la capacidad de here-

dar. Igualmente al estado romano, a la Iglesia y a las corporaciones pías. Del mismo modo, el dejar la herencia a los dioses —en la época pagana—, a Dios o a los santos —en la época cristiana—, irá en provecho, bien del estado romano, bien de la Iglesia.

(D) En cuanto a las mujeres, por la *lex Voconia* se les prohibió adquirir como herederas por testamento de quienes estuvieran en la primera clase —los más ricos, que eran aquellos que poseían una fortuna superior a los 100.000 ases—, aunque, de todos modos, podían adquirir por legados hasta una cantidad igual a la de los herederos.

- Esta ley, atribuida al tribuno Voconio Saxa —año 169 a. C.—, pretendía evitar la existencia interesada de vínculos hereditarios, pero a comienzos del Imperio comenzó a caer en desuso.

(E) Por la *lex Iulia de maritandis ordinibus* —año 17 a. C.—, y por la *lex Papia Poppaea* —año 9 a. C.—, con el fin de fortalecer a la familia romana se dispusieron una serie de incapacidades respecto de aquellos que no se casaban; o que casados, no tenían hijos.

- Estas leyes —denominadas "caducarias" porque la parte de los sancionados se vuelve *caduca* en favor del fisco— determinaban que los *caelibes* —hombres que estuviesen entre los 25 y 60 años y mujeres de entre 20 a 50— que no se casaban perdían lo que hubieran adquirido por herencia o legado. Otro tanto ocurría con los *orbi* —hombres de la edad antedicha, casados y sin hijos y mujeres con menos de tres hijos (*ingenuas*), o con menos de cuatro (*libertas*)—, que perdían la mitad de lo que les correspondía. También el *pater solitarius* —viudo sin hijos— entró, quizá, en esta categoría.
- Igualmente el cónyuge que estuviese en similares circunstancias sólo podía, en principio, adquirir del otro una décima.

La *testamenti factio passiva* se debía tener no sólo en el momento de la *factio* del testamento, sino también en el momento de la muerte del testador. A estos dos requisitos —época clásica—, Justiniano agregará el de ser capaz en el momento de aceptarse la herencia —doctrina de los tres momentos.

109

504 1

101

CONTENIDO DEL TESTAMENTO

Institución de heredero. — El fin esencial del testamento romano es designar uno o varios herederos a los efectos de ocupar la situación jurídica que tenía el causante. De allí la importancia que poseía la *heredis institutio* (institución de heredero), de la cual va a depender la eficacia de todas las otras cláusulas que pueda contener este negocio de última voluntad.

- Por ello es que la cláusula de la institución de heredero debía, en la época clásica, figurar al comienzo. Las otras cláusulas, tales como los legados, los fideicomisos, la dación de tutor, la manumisión de heredero, serán ineficaces si no figura aquélla; o nulas, si el heredero no acepta la herencia.
- En la época justiniana este principio se debilitará un poco. Se permitirá que la *heredis institutio* figure en cualquier parte del testamento, y no necesariamente a la cabeza; incluso, dada la vigencia que tenía el codicilo —que no requería la institución de heredero—, la línea de separación entre éste y el testamento se irá desdibujando mucho.
- La formulación debe ser imperativa. Así, la forma corriente es: "*Titius heres esto*" ("Que Ticio sea heredero"). También se permite, en la época clásica, esta otra forma: "*Titium heredem esse iubeo*" ("Ordeno que Ticio sea heredero").
- En cambio, una forma no tan directa como "quiero que Ticio sea heredero" no es válida en la época clásica. Esta rigidez se atenuará en la época de Constantino, quien permitirá (año 320 d.C.) un empleo más libre de las palabras e, incluso, que puedan ser formuladas en griego.

(A) La institución de heredero —como supone una sucesión universal— no podía ser hecha respecto de una cosa determinada. En efecto, el heredero lo es de toda la herencia o de una parte si concurre con otros, pero instituirlo *ex re certa* (respecto de una cosa determinada) repugnaría al derecho. Sin embargo, como aplicación de un principio de validez del testamento —*favor testamenti*—, se lo tendrá por válido como si la cláusula "por cosa determinada" no se hubiera escrito.

- Esta interpretación arranca de Sabino. Pero en la época clásica se determinará que cuando se produzca la división de la herencia, el *arbitrator* (árbitro) en la *actio familiae erciscundae* tratará de adjudicar las cosas según la voluntad del testador, compensando los sobrantes en dinero y repartiendo proporcionalmente las deudas.
- Probablemente, la institución *ex re certa* haya tenido en su origen algo que ver con la adjudicación del predio, en tanto éste era un elemento fundamental para un pueblo de mentalidad agrícola como el romano.

- En la época de Justiniano, a estos herederos se los llama adjudicatarios de un prelegado o que están en la situación de legatarios (*loco legatarii*), de tal modo que no se les permite reclamar más que la cosa atribuida por el testador.

(B) La institución de heredero puede subordinarse a un plazo o una condición suspensivos, pero no resolutorios.

- Ello se expresa en una regla que dice "*semel heres semper heres*" ("una vez heredero, se es siempre heredero"), con la cual se destaca la no limitación temporal una vez que se ha establecido quién es el heredero; en la suspensiva, en cambio, hasta que no se cumpla la condición —o el plazo—, no llega el instituido a ser heredero, lo cual no va contra la regla mencionada.

(C) La institución puede ser respecto de un heredero o respecto de varios. En esta última circunstancia —salvo lo dicho para el caso especial de la institución *ex certa re*—, la división se hace por fracciones o cuotas numéricas.

- El sistema romano es a este respecto duodecimal, de tal modo que todo el patrimonio —as— se divide en doce onzas (*unciae*). Así, *uncia* = un duodécimo; *sextans* = sexta parte o dos *unciae*; *quadrans* = cuarta parte o tres *unciae*; *triens* = tercera parte o cuatro *unciae*; *quinarius* = 5 *unciae*; *semis* = mitad o 6 *unciae*; *septunx* = 7 *unciae*; *bes* = 8 *unciae*; *dodrans* = 9 *unciae*; *dextans* = 10 *unciae*; *deunx* = 11 *uncia* y *as* = el todo o doce *unciae*.
- No es necesario que el testador haga una asignación detallada; en tal caso se distribuye en partes iguales.
- Si instituyera a un solo heredero y le dejara un número limitado de cuotas, por ejemplo 6 onzas, el resto no podría ir a los herederos *ab intestato* porque, salvo el caso del testamento militar, "no se puede morir en parte testado y en parte intestado". En ese supuesto, las cuotas se aumentan hasta agotar el capital íntegro.

Substitución de herederos. — Se puede dar el supuesto de la substitución de heredero a fin de que si el heredero instituido en primer término no puede llegar a serlo, lo sea otro u otros. Los romanos conocieron tres clases de substitución.

(A) **Substitución vulgar** (*substitutio vulgaris*). — Ocurre cuando se instituye un heredero substituto para el caso de que el instituido en primer término haya premuerto en relación al causante o haya repudiado la herencia.

- Así, por ejemplo: "Que Ticio sea mi heredero. Si no llegara a serlo, que lo sea Mevio." El propósito evidente es asegurar el cumplimiento del testamento.

(B) Substitución pupilar (*substitutio pupillaris*). — Ocurrir cuando el testador instituye heredero a un *filius* impúber, designando a otro como substituto para el supuesto de que aquél falleciere antes de llegar a la pubertad.

- En este caso estaríamos ante una situación de este tipo: "Que mi hijo Ticio, impúber, sea mi heredero. Pero si llegare a morir antes de ser púber, que lo sea Mevio." Este supuesto es el que se presentó en la célebre *causa Curiana*.
- Cabe advertir acá que el testador estaría haciendo no sólo su testamento, sino prehaciendo el testamento del heredero. Por ello, durante la época clásica se lo consideró al substituto un heredero del impúber. Esta capacidad nacería para el *pater* del ejercicio de la *patria potestas*.

(C) Substitución cuasi pupilar (*ad exemplum pupillaris substitutionis*). — En la época justiniana se admite que si el *pater* instituye como heredero a un *filius* demente (*furiosus*), debido a la enfermedad que éste padece se le permite —a semejanza del caso anterior— instituirle un substituto para la eventualidad de que llegase a morir sin haber recobrado la razón.

- Si el demente tiene descendientes, el heredero substituto debe ser elegido de entre ellos; de lo contrario debe ser elegido un descendiente del *de cuius*; si no existe, cabe la libre elección.

INVALIDEZ Y REVOCACION DE LOS TESTAMENTOS

I. Un testamento puede resultar inválido por diversas causas. La terminología utilizada por los romanos era la siguiente.

(A) Se llama *testamentum iniustum* o *non iure factum* (no hecho de acuerdo a derecho) aquel al que le faltan requisitos de forma, verbigracia, los testigos— o de fondo —verbigracia, la *testamenti factio* * del testador o del heredero—. En estos casos el testamento es nulo desde el inicio.

(B) Un testamento válido en cuanto a sus formas y requisitos de capacidad puede ser, sin embargo, *inutile* cuando el testador ha cometido la preterición * de un *heres suus* *.

(C) Siendo inicialmente válido, se puede volver con posterioridad *irritum* (anulado) en el supuesto de que el testador haya caído en una *capitis deminutio* * —aunque fuere *minima*—

y sin perjuicio de lo establecido a propósito del *ius postliminii* * y de la *fictionis legis Corneliae*.

(D) También se puede volver *ruptum* (quebrado) para el supuesto de que con posterioridad naciera un *heres suus* —varón—, por cuanto quedaría preterido.

(E) También se puede volver *desertum* (abandonado) o *destitutum* (frustrado) para el supuesto de que los herederos hayan premuerto respecto del testador, o porque no se acepte la herencia, o cuando, sujeta la institución de heredero a una condición suspensiva, ésta no se cumpliera.

II. A su vez, un testamento puede ser revocado. Se entiende por revocación la invalidez de un testamento por una declaración contraria del testador.

(A) En el primitivo derecho —dada la rigidez de las formas para hacerlo—, la idea de revocación resulta extraña al Derecho Romano. Pero luego —a medida que se va aceptando sobre todo la forma del testamento pretoriano— se va a entender que todo testamento puede ser revocado por el otorgamiento de uno nuevo.

- La facción de un testamento nuevo revoca al anterior, aunque el nuevo se torne *desertum* por no aceptar los herederos en él instituidos la herencia.

(B) Si el testamento resulta destruido en su materialidad o el testador ha roto la cinta que con sus respectivos sellos lo mantenían cerrado, el testamento carece de valor. En este supuesto el pretor denegará a los herederos designados la *bonorum possessio secundum tabulas*, otorgando, en cambio, una *bonorum possessio intestati* a los herederos legales *ab intestato*.

- Esta última será *cum re*, o sea, con posesión definitiva de los bienes hereditarios.

(C) Cuando llegamos al derecho posclásico, se van afirmando dos formas de revocación. La primera era de carácter formal y debía hacerse por el testador mediante una declaración jurada ante cinco testigos, con el fin de incluir herederos *ab intestato*. La segunda era informal, ya por el otorgamiento

110

504 1

109

de un nuevo testamento o por la destrucción o apertura intencionada del testamento por parte del testador.

(D) En la época de Justiniano se puede revocar el testamento por la simple declaración de voluntad manifestada por el testador ante tres testigos o ante la autoridad judicial, una vez transcurridos diez años de haber sido otorgado.

SUCESION CONTRA EL TESTAMENTO

En principio el testador tiene una genérica libertad de testar, en virtud de la cual —como ocurrió en un comienzo— el *pater* podía desheredar a alguno o a todos sus *filiifamilias*. Esta libertad, que supone un grado marcado de individualismo, puede contrariar los intereses de aquellos familiares llamados a heredar al causante conforme con las reglas de la herencia *ab intestato*, intereses que se enmarcaban en un principio de comunidad familiar.

Este conflicto tendrá, a través del tiempo, planteos distintos. En efecto, por un lado se tratará de garantizar a los herederos legítimos contra ciertas deficiencias formales habidas en el testamento. Se trata acá de la sucesión necesaria formal. En cambio, a partir de un muy interesante desarrollo, se irá admitiendo que, no obstante no haber deficiencias formales, aquellos herederos legítimos pueden, sin embargo, reclamar contra el testamento que los excluyó. Se tiene, entonces, la sucesión necesaria material.

LA SUCESION NECESARIA FORMAL

En el viejo *ius civile*, el testador tenía un deber respecto de los *filiifamilias*, puesto que, si bien era libre ya de instituirlos herederos, ya de desheredarlos, lo que no podía hacer era preterirlos, es decir, silenciarlos no nombrándolos en el testamento,

- La *exheredatio* debía hacerse al comienzo del mismo testamento empleando las palabras rituales, aunque de significado contrario a las que habíamos visto en la "institución de heredero". Así, por ejemplo: "*Titius filius meus exheres esto*" ("Que Ticio, hijo mío, sea desheredado").
- A fines de la República se acostumbrará a que los hijos sean desheredados en forma nominativa (*nominatim*), es decir, nombrándolos por su nombre propio. En cambio, las hijas y otros descendientes podían ser desheredados en bloque —*inter ceteros*—. Verbigracia: "Que mi hijo Ticio sea heredero y que los restantes sean desheredados".
- En virtud de la regla mencionada, si luego de hecho un testamento nacía un *filius* del testador, se volvía *ruptum*, por lo que perdía validez. Para poder prevenirse respecto de los herederos póstumos —nacidos después de la muerte del testador— se admitió la *exheredatio* de éstos.

I. El efecto de la preterición de un *heres suus* * era el de arrastrar la nulidad del testamento. Sin embargo, por una interpretación posterior debida al tribunal de los centunviros se admitió que este efecto sería sólo si el preterido fuera un *filius*. En cambio, si se trataba de la hija o del nieto, se interpretaba que a la persona omitida se la tuviera "como por inscripta" (*quasi scripta*), participando de una parte igual a la de los otros herederos, si éstos eran *heredes sui*; y con la mitad de la herencia, si se trataba de "herederos extraños".

II. El pretor continuará con las normas ya señaladas, poniéndolas en coordinación con la *bonorum possessio* *.

(A) Todos los hijos varones debían ser instituidos o desheredados en forma nominativa. Pero con que se presentase un solo caso de preterido, el testamento se convertía en nulo, por lo que correspondía abrir la herencia *ab intestato*, concediéndoles a todos los interesados y llamados en la clase *unde liberi* * la *bonorum possessio*.

(B) Si se trataba de nietos —debían también ser instituidos o desheredados en forma "nominativa"— o de hijas, o de la *uxor in manu* * —podían ser desheredadas en forma global—, el testamento no se volvía *inutile*, pero a los preteridos se les concedía la *bonorum possessio contra tabulas* (contra las tablillas [del testamento]).

- Esta *bonorum possessio contra tabulas* será siempre *cum re* *, a la que el pretor le otorgaba mayores ventajas que a las concedidas por el *ius civile*. En efecto, si se pretería a una hija y los herederos eran sus hermanos, seguía teniendo aquella una "cuota viril" —una parte igual a la

de ellos—; pero si era respecto de extraños, entonces éstos quedaban excluidos por la totalidad, mientras que por el *ius civile* mantenían la mitad.

- Por un rescripto de Antonino Pío se restringió nuevamente su situación y sólo pudo adquirir la mitad que le correspondía por el *ius civile*.

III. En el derecho posclásico —sobre todo a partir de la época de Constantino, quien no consideró necesario el empleo de palabras formales en los testamentos— bastaba cualquier forma para instituir o desheredar.

Pero Justiniano precisó que, tanto para un descendiente varón como para una mujer, era necesaria la desheredación nominativa, suprimiendo en cambio la global (*inter ceteros*).

- La consecuencia más importante de esta equiparación era que la preterición —se tratase ya de un hijo, un nieto o una hija— arrastraba la nulidad del testamento, abriéndose la herencia *ab intestato*.
- Dejó, sin embargo, establecida una diferencia para el hijo emancipado, cuya preterición no arrastraba la nulidad, puesto que podía pedir la *bonorum possessio contra tabulas*.

LA SUCESION NECESARIA MATERIAL

Al declinar los tiempos republicanos, el auge del individualismo y hedonismo, la liberación de las costumbres y la disolución de la familia tradicional llevaron a que algunos romanos realizaran muchas veces sus testamentos de acuerdo con una muy personal afectividad, olvidando en absoluto los deberes que el estado de familia les imponía respecto de sus hijos, mujer u otros parientes. Cuando el testamento era válido y no había deficiencias formales como las ya analizadas, los antedichos se encontraban, por el capricho muchas veces fantasioso del testador, sin el goce de la herencia y sin poder reclamar nada por la vía judicial.

Es entonces que los juristas —sobre la base de que el testador no cumplía en esos casos con el deber familiar y había obrado *contra officium pietatis* (contra el deber del afecto)— comenzaron a hablar de que el testamento resultaba *inofficiosum* (contrario al deber).

Querela inofficiosi testamenti. — En virtud de estas ideas es que se admitió un procedimiento especial denominado la

querela inofficiosi testamenti. Por su intermedio, más que polemizar sobre lo estrictamente jurídico, se admitía una amplia discusión sobre si el testador había infringido o no el *officium pietatis* respecto de sus parientes próximos, por haberlos excluido del testamento o haberles dejado bienes en cantidad muy menguada.

- El procedimiento comenzó a tramitarse —por lo menos para las grandes sucesiones— ante el tribunal de los centunviro; para las más pequeñas se admitió el procedimiento formulario y más tarde el *extra ordinem*.
- La forma especial que revestía este juicio permitía amplios debates que daban lugar al lucimiento de los oradores, máxime porque debía argumentarse para cada caso en particular. Muchas veces el juicio dependía de la eficacia de los argumentos empleados, siendo interesante señalar que uno de los más empleados era suponer que el testador que había olvidado de modo tan ímpio a sus parientes próximos lo hacía porque habría obrado bajo los efectos de una perturbación mental (*color insaniae*).
- Luego se admitió, sin necesidad de recurrir a la ficción de la insania —que, obviamente entrañaba la nulidad inicial del testamento— que éste era *inofficiosum* por la mera violación de la *legítima*, es decir, una determinada proporción de lo que legítimamente hubiera correspondido si la sucesión hubiera sido *ab intestato*.

I. La *querela inofficiosi testamenti* fue lentamente estructurada sobre la base de determinadas condiciones de ejercicio.

(A) Tenía la facultad de ser ejercitada por los hijos del testador que se hubieran podido presentar a la herencia *ab intestato* —tanto civil como pretoriana— y alcanzaba también a los ascendientes y a los hermanos.

- Por una constitución de Constantino se excluyó a los hermanos uterinos —es decir, los nacidos de una misma madre aunque de distintos padres—, pero admitiéndosela para los hermanos consanguíneos —del mismo padre y de distinta madre— y para los gemelos —del mismo padre y de la misma madre—, pero siempre que el heredero testamentario fuese una persona indigna (*turpis persona*).

(B) Sólo podía ser intentada en el plazo de cinco años y no se transmitía a los herederos del legitimado.

- Por una constitución del año 258 d. C. se estableció que respecto de los *minores* esta prescripción de cinco años sólo comenzaba a ser computada a partir de que tuvieran 25 años.

111

504 1

110

(C) La *querela* era llevada a cabo contra el heredero, o herederos, instituidos en el testamento. De progresar su efecto, se anulaba el testamento, abriéndose la sucesión *ab intestato*.

- * Sin embargo, no todo el testamento resultaba nulo. Seguían siendo válidas cláusulas como manumisiones, legados, nombramientos de tutores.
- * Incluso podía suceder que ciertas instituciones de herederos continuaran teniendo valor. Casos de este tipo eran, por ejemplo, la del instituido heredero que ya anteriormente había resultado victorioso en otro proceso de *querela*; o la del heredero instituido juntamente con otro y respecto de los cuales un hermano del testador había iniciado *querela*, triunfando en uno de los casos pero siendo derrotado en el otro por no poder probar que se trataba de una *turpis persona*.
- * En estos supuestos se admitía como excepcional la derogación de la regla de que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado.

(D) El querellante debía demostrar no sólo su eventual vocación hereditaria *ab intestato*, sino que además había sido perjudicado por su exclusión —caso éste en que el perjuicio era evidente— o por la disminución de la parte que le correspondía.

En un principio, los jueces apreciaban de manera muy libre cuándo debía progresar la *querela*, pero luego se fue admitiendo —por influencia de la *lex Falcidia*— que para poder progresar era necesario que el heredero quejoso hubiera recibido menos de un cuarto de la porción debida según el régimen legítimo *ab intestato*.

II. Se planteaba acá una evidente inconsecuencia, ya que si el testador hubiera dejado al heredero esa cuarta parte de la herencia, éste no tendría más derecho a pedir la *querela inofficiosi testamenti*; en cambio, si le dejaba menos de esa parte "legítima", entonces, por la *querela*, obtenía la caída del testamento y con la exclusión del heredero testamentario podía, eventualmente —de no existir otros herederos— quedarse con la totalidad de la herencia.

Para remediar esta incongruencia se fue abriendo paso en el derecho posclásico el otorgamiento de una acción —*actio ad supplendam legitimam*— por medio de la cual el heredero no instituido podía demandar que se supliere lo que le faltaba hasta cubrir la porción legítima, dejándose subsistente el resto del testamento.

* Esta acción se debió, en principio, a una constitución del año 361 d. C., ya que se había presentado el caso de un testador que había dejado ciertos bienes a sus hijos con el agregado de que si aquéllos eran inferiores a la legítima, que ella fuera completada "según el arbitrio de un honesto hombre" (*boni viri arbitratu*). Los emperadores Juliano y Constancio admitieron por dicha constitución la procedencia de esta acción supletoria.

* Esta *actio supplendam legitimam* se diferencia de la *querela* en que es *in personam* —reclama el suplemento, al heredero instituido, como un crédito— y no *in rem* —como en la *querela*, por la que se pretende obtener toda la herencia—. Además, no se le aplica la prescripción de los cinco años y pasa a los herederos. Por último, si el heredero pierde esta acción, no pierde las liberalidades ya acordadas.

III. Justiniano dará por medio de tres constituciones —una del año 528, y luego las novelas 18 y 115— formas definitivas a esta evolución de la *querela inofficiosi testamenti*, aceptando las diversas modificaciones producidas. El régimen quedaría establecido del siguiente modo.

(A) Aumenta la *portio legitima* de un cuarto hasta un tercio cuando los herederos intestados no pasan de cuatro, y hasta un medio cuando son más de dicho número.

* Esto daba lugar a una incongruencia: Si había cuatro herederos, cada uno de ellos tenía como legítima una dozava parte; en cambio, si eran cinco, cada uno de ellos tenía un décimo.

(B) Si un heredero familiar próximo —descendiente, ascendiente o hermano— hubiese sido preterido o desheredado sin justa causa, se le concedía la *querela inofficiosi testamenti*, la cual, si bien conserva el antiguo nombre, ahora funciona de acuerdo con las modificaciones posclásicas.

De este modo, si fue totalmente excluido de la herencia, funciona como una *petitio hereditatis* por el monto de la *pars legitima*. Si, en cambio, lo que le ocurrió es que se le dejó una suma inferior a la *pars legitima*, entonces funciona como la *actio supplendam legitimam*.

* En ambos casos, el testamento no queda eliminado, sino que el heredero legítimo sustituye al instituido hasta el límite de la *portio legitima*.

(C) Se establecen de manera taxativa cuáles son las cau-

sas posibles de desheredación que debe invocar el testador respecto de los herederos con derecho a la *portio legitima*.

- Estas causas —capítulos III y IV de la novela 115— figuran especificadas con mucho detalle. En el capítulo III, que contiene catorce en total, se señalan las que pueden invocar los ascendientes respecto de los descendientes. Por ejemplo, el haber atentado contra la vida, o el honor o el haber puesto las manos en los ascendientes; el haber vivido como malhechor entre malhechores o haber vivido con atletas del circo o mimos del teatro a menos que los ascendientes fueran de ese oficio; el no haber prestado auxilio al ascendiente incapacitado (*furiosus*) o el no haberse dispuesto a rescatarlo de haber estado cautivo del enemigo; si fuere el ascendiente de la religión católica y los descendientes no abrazaran esa religión, etcétera.
- A su vez, en el capítulo IV se mencionan ocho situaciones como causales de desheredación de ascendientes, siendo las principales el haber atentado contra la vida o abandonado al descendiente; o haber atentado contra su honor teniendo comercio carnal con la mujer o concubina del descendiente; o haber incurrido en las mismas causales de falta de auxilio en caso de incapacidad o cautiverio, y también, siendo católico, el observar que sus ascendientes no profesan esa religión.

(D) Se mantienen en esta época las dos variantes admitidas desde el derecho posclásico, que eran la llamada *querela inofficiosae donationis* —admitida por primera vez por Alejandro Severo—, por la cual se podían anular las donaciones excesivas efectuadas por el testador *inter vivos* que perjudicaran la *pars legitima*, de tal modo que lo donado regresara a la herencia, y la *querela inofficiosi dotis* —el antecedente es del emperador Zenón—, por medio de la cual se anula la dote excesiva cuya constitución hubiese agotado el patrimonio y por ello perjudicado la *pars legitima*.

LOS LEGADOS, LOS FIDEICOMISOS Y LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE

LOS LEGADOS

Se entiende por legado una disposición *mortis causa* incluida en un testamento —o en un codicilo confirmado— con cargo al heredero instituido de que realice o permita realizar una transmisión a título singular a otra persona llamada legatario.

- Se trata de una cláusula accesoria de un testamento, de tal modo que su validez dependerá de la suerte de la institución de heredero y, en general, del mismo testamento.

CLASES

I. En la época clásica se distinguen cuatro clases de legados solemnes.

(A) Legado *per vindicationem*. Es la forma más antigua de legado de propiedad, ya que por él se transmite el dominio *ex iure Quiritium* de una cosa del testador. Se establecía así: "Doy, lego mi esclavo Sticho a Ticio".

- La propiedad de las cosas legadas pasa directamente al legatario, sin intermediación del heredero. De ahí que si el heredero no cumplía el legado, el legatario podía reclamar la cosa por una reivindicación.
- Igualmente se pueden transmitir el usufructo o una servidumbre, teniendo entonces el legatario, según el caso, una *vindicatio usus fructus* o *servitutis*.
- Los sabimianos sostenían que el legatario se hacía propietario, aunque no conociera el legado, desde la muerte misma del causante. Los proculyanos, en cambio, decían que el legatario debía expresar previamente su asentimiento.
- Las cosas legadas debían pertenecer al *dominium ex iure Quiritium* del testador, tanto en el momento de la facción del testamento como en el de la muerte. Se excluían las cosas fungibles, las cuales sólo debían ser del testador en el momento de la muerte.

(B) Legado *per damnationem*. Se trata de una forma de legado de condena (*damnatio*) por medio de la cual se obliga al heredero que aceptó la herencia a realizar una prestación en favor del legatario. Se la determinaba de este modo: "Que mi heredero sea constreñido a dar mi esclavo Sticho a Ticio".

- Representa el legado más amplio, ya que las cosas pueden ser del testador, del propio heredero o, incluso, de un tercero. Acá el heredero queda obligado a adquirirla del tercero; y si esto no es posible, a pagar el valor de ella.
- Pero también puede adoptar otras modalidades. Así, el *legatum nominis*, por medio del cual se deberá permitir que el legatario ejecute las acciones para cobrar un crédito; el *legatum liberationis*, con el cual el legatario queda liberado de una obligación que debía al causante; el *legatum debiti*, con el que se ordena al heredero que pague al legatario una deuda del causante con alguna ventaja —por ejemplo,

112

504 1

000

teniendo por cumplido un plazo—, ya que, de lo contrario, no sería legado, puesto que se reduciría indudablemente, a una obligación debida; el *legatum partitionis*, que otorga al legatario la facultad de repartirse con el heredero una cierta proporción de la herencia.

- * Las cosas legadas pueden ser especificadas concretamente —*legatum speciei*— o ser genéricas: —*legatum generis*—, como lo son el vino, el trigo, etcétera. Pueden igualmente consistir en cosas futuras, constitución de una dote, prestaciones periódicas, alimentos, y otros.
- * El legatario no adquiere directamente las prestaciones, sino por intermedio del heredero; y si éste no cumple, lo debe demandar como deudor en virtud de la *actio ex testamento*.

(C) Legado *sinendi modo*. Se trata de una forma de legado de permisión por medio de la cual el heredero deberá permitir que el legatario se apropie de una cosa del patrimonio del testador o del suyo propio. Se realizaba así: "Que mi heredero tenga que tolerar que Ticio tome y adquiera para sí a mi esclavo Sticho".

- * Como consistía en un permitir (*sinere*), se entendió en un comienzo que el legatario podía aprehender directamente la cosa y ejecutar directamente al heredero mediante la *manus iniectio*. Posteriormente se aceptó que el heredero era un deudor del legado y se le concedió al legatario la *actio incerta ex testamento*.
- * Se diferencia del *per damnationem*, ya que acá sólo se pueden legar cosas del testador o del heredero.

(D) Legado *per praeceptionem*. *Praecipere* significa tomar algo con anticipación. Los sabinianos —recogiendo el pensamiento antiguo— entendían que este legado se podía dejar sólo a un heredero, quien, por medio de la *actio familiae erciscundae*, podía, en el momento de la partición, conseguir con anticipación a los demás la cosa legada.

En cambio, los proculeyanos entendían que por este legado se podía favorecer a un tercero: por ello decían que la partícula *prae* —con idea de anticipación— estaba demás y sólo debía decirse "*capito*" ("que tome"). Lo trataban, en consecuencia, como un legado *per vindicationem*.

II. En una etapa posterior —comenzada por el senadoconsulto Neroniano*, entre el 54 y el 68 d.C.— se va a ir debilitando la exigencia formal y la diferencia entre estas clases de legados.

En efecto, se determinó por dicho senadoconsulto que si un legado resultaba inválido de acuerdo con los requerimientos de la forma adoptada por el testador, no obstante ello no perdía su validez, entendiéndose que se lo debía considerar como hecho *per damnationem*, el más amplio de todos.

III. Más adelante, y congruentemente con la disposición de Constantino —año 320 d.C.—, que permitiría una libertad no formal en cuanto a la institución de heredero, se autorizó igualmente a prescindir de la *sollemnitas verborum* (solemnidad de las palabras) en los legados.

Finalmente, Justiniano establecerá que todos los legados debían tener una sola naturaleza (*unam naturam*), pudiéndose derivar de ellos ya una *actio in rem* —supuesto de legarse una cosa del testador o del heredero— o una *actio in personam* —supuesto de prestaciones obligacionales a cumplirse en favor del legatario—.

- * No debemos olvidar, por otra parte, que la naturaleza del vínculo obligacional que tienen los legados es considerada por Justiniano como un *quasi ex contractu*.
- * Además, esta lenta pérdida de la formalidad de los legados los ir- acercando a los fideicomisos, con los cuales finalmente se igualarán.

REGIMEN DE APLICACION DE LOS LEGADOS

Adquisición.—De acuerdo con el principio general, el legado dependerá del testamento y éste de la institución de heredero. El legatario debía esperar que el heredero aceptara la herencia si se trataba de un *extraneus**, ya que el forzoso —heredero suyo y necesario y heredero necesario— la adquiriría automáticamente.

Esta solución podía traer inconvenientes si el heredero, teniendo en vista que el legatario fuese un valetudinario o un enfermo grave, retardase la aceptación de la herencia especulando con salvarse de tener que cumplir la carga del legado.

Por ello los romanos determinaron como punto crucial la determinación de lo que llamaron el *dies cedens*, el día en que nacía el derecho al legado.

(A) Para los legados puros y simples ese momento quedaba determinado en la muerte del testador. A partir de ese momento nacía una expectativa concreta —dependiente de la aceptación del heredero, si éste era un *extraneus*—. Ese derecho de expectativa era transmisible a los eventuales herederos del legatario, quienes de este modo no se perjudicaban. Cuando luego ocurría la aceptación del heredero el legatario o sus herederos podían reclamar efectivamente el legado. Este nuevo momento es llamado *dies veniens*, el día en que efectivamente se puede materializar el legado.

- * La *lex Papia Poppaea* —época de Augusto— determinó el momento del *dies cedens* en la apertura del testamento; Justiniano lo retrotrajo al momento de la muerte del testador.
- * El legado concedido a un esclavo manumitido no es anticipado en el *dies cedens*, ya que de computarse en el momento de la muerte del testador, el legado iría a parar al instituido heredero por el principio de que todo lo que adquiriese el esclavo era para su dueño. En efecto, hay que tener en cuenta que el esclavo no será libre hasta la aceptación de la herencia. En consecuencia, para no perjudicarlo, se estableció que el *dies cedens* coincidiera con la *hereditatis aditio*. *

(B) Si se trata de un legado a plazo cierto, el *dies cedens* ocurrirá igualmente el día de la muerte del testador, pero deberá de todos modos transcurrir el lapso establecido para que aconteciese el *dies veniens*.

(C) En cambio, si el legado está sujeto a un plazo incierto o a una condición, el *dies cedens* no ocurre sino después de que éstos se hayan cumplido.

- * La asimilación de los legados a plazo cierto con los puros y simples era correcta por cuanto podía establecerse que en ambos el testador había querido otorgar en firme los legados, no ocurría lo mismo en los condicionales o de plazo incierto.

Ineficacia y revocación de los legados.— Un legado podía ser ineficaz por invalidez del testamento donde estuviese incorporado o por causas propias del legado, como fuese por incumplimiento de las formas, falta de capacidad para transmitirlo, vicio de la voluntad o por su contenido ilícito.

Se aplicaba acá la denominada *regla Catoniana*, según la cual, si el legado era nulo en el momento de hacer testamento, no podía hacérselo valer posteriormente. Esto significa que el momento para la consideración de la nulidad es el de la celebración del testamento; y si hubiera una causa de nulidad, ésta no podría ser convalidada posteriormente.

- * Un legado que en principio es válido, puede resultar inválido por un hecho posterior. Así, por ejemplo, cuando el legatario fallece antes del *dies cedens*, o la cosa legada se extingue o se vuelve *extra-commercium* *.

Finalmente, un legado puede ser revocado por propia decisión del testador mediante una fórmula contraria, como en el caso: "No doy, no lego a Ticio" —legado *per vindicationem*—; o: "Que no le sea dado por mi heredero a Ticio" —legado *per damnationem*.

LIMITACIONES A LA FACULTAD DE LEGAR

En el viejo derecho era lícito para el testador otorgar en forma ilimitada los legados. Así lo permitía la ley de las XII tablas, que establecía que "*Uti legassit suae rei, ita ius esto*" ("Todo aquello que dispusiera por legado de sus cosas, que eso sea derecho"). Esto comenzó a traer problemas, por cuanto la herencia, cuando era muy gravosa por la gran cantidad de legados, los herederos se abstendían de la misma, por lo que al no ser aceptada caía el testamento y se tenía que abrir la herencia *ab intestato*, perdiéndose los legados.

I. Para solucionar este inconveniente se dictó la *lex Furia* (posiblemente hacia el siglo II a.C.), según la cual —salvo parientes próximos, cognados hasta el sexto grado— los legatarios no podían adquirir como tales más de mil ases.

- * Esta ley resultó vana; ya que bastaba que el testador repartiera su patrimonio —por ejemplo, de 5.000 ases— en cinco legados, para dilapidar la herencia y no dejar nada al heredero.

113

II. Se sancionó luego la *lex Voconia* (año 169 a.C.), según la cual, ya fuera por legado, ya por causa de muerte, nadie podía adquirir más de lo que adquirirían los herederos.

- * Pero también esta ley era fácilmente burlada, ya que el testador podía distribuir su patrimonio en muchos legados a distintas personas, iguales o inferiores a lo que le quedaba al heredero, quien dejaba de tener interés en la aceptación de la herencia.

III. Se aprobó entonces la *lex Falcidia* (año 40 a.C.), por la cual le era lícito al testador legar las tres cuartas partes de la herencia siempre que reservara al heredero una cuarta parte (*quarta Falcidia*).

- * El cómputo debe hacerse deduciendo del activo calculado en el momento de la muerte todas las deudas, los gastos funerarios y el valor de los esclavos manumitidos; de este modo se establece el patrimonio neto sobre el cual se debe computar el monto de los legados; si éstos son inferiores a las tres cuartas partes, no hay problemas y todos los legatarios cobran la totalidad de sus respectivos legados. Si por el contrario, son mayores en cuantía a las tres cuartas partes del patrimonio neto, entonces el heredero reserva para sí una cuarta parte, debiéndose repartir el resto —a prorrata— entre los legatarios.
- * De haber varios herederos, cada uno debía computar individualmente su cuarta parte —pudiendo resultar que uno estuviera por las disposiciones del testamento más gravado de legados que otro—, pero de tal modo que cada cuota hereditaria quedara libre de legados en una cuarta parte de su cuantía.
- * La *lex Falcidia* no se aplica a los testamentos militares, ni a los legados piadosos; tampoco a los legados de dote —por considerarse que la mujer recibe la cosa suya— ni a los legados de manumisión de un esclavo.

LOS FIDEICOMISOS

En general, se entiende por fideicomiso (*fideicommissum*) un ruego hecho de manera informal por el causante, por medio del cual se encomienda a una persona que cumpla algo, confiando en su buena fe (*fides*).

- * En todo fideicomiso tenemos tres personas: el *fideicomitente* —el que encarga el fideicomiso—, el *fiduciario* —el que se compromete a realizarlo— y el *fideicomisario* —el finalmente beneficiado.

- * Mientras que el legado es formal y debe ser hecho con palabras imperativas, el fideicomiso es informal, hecho con lenguaje oblicuo y en forma rogativa: "Te pido, te ruego, quiero que, confío en tu buena fe", etcétera.

Los fideicomisos pueden ser a título universal, en cuyo caso nos encontramos frente al fideicomiso de herencia o a título particular, en cuyo caso se da el supuesto de fideicomiso singular.

- * El fideicomiso universal tiende a parecerse a la herencia, mientras que el fideicomiso singular tiende a parecerse al legado.

DESARROLLO HISTÓRICO

I. Durante una primera etapa el fideicomiso sirvió para superar el formalismo exigido para los legados y también ciertos inconvenientes para hacer testamento. Así, cuando no existía la *testamenti factio passiva* o cuando por las circunstancias no había posibilidad práctica de testar de acuerdo con las formas.

Se acostumbraba, entonces, encomendar la última voluntad a otra persona en una relación basada en la *fides*; pero la obligación del cumplimiento del negocio era meramente moral.

II. Luego, "a causa de la insigne perfidia de ciertas personas", como dice Justiniano en relación con los que no cumplían lo encargado, Augusto admitió la coercibilidad de algunos fideicomisos, substanciándose las causas de los quejosos ante el cónsul —*extraordinaria cognitio**—. Luego, en la época de Claudio, se estableció un pretor especial para estos casos (*praetor fideicommissarius*).

III. La tercera etapa estuvo señalada por la reglamentación de los fideicomisos por medio de los senadoconsultos Trebelliano y Pegasiano, luego analizados.

IV. Finalmente, respecto de los fideicomisos a título singular, se los fue acercando a los legados, a medida que éstos comenzaron a perder los requisitos de las formalidades y en tanto que fueron aumentando los recaudos y una mayor protección de los fideicomisos, de tal modo que en la época de Jus-

tiniano, a pesar de seguir conservando las denominaciones de *legatum* y *fideicommissum*, ambos institutos quedaron equiparados.

LOS FIDEICOMISOS PARTICULARES

Por medio de estos fideicomisos se rogaba al heredero —ya fuese testamentario, *ab intestato* e, inclusive, fideicomisario— o al legatario que transmitiera, a título singular, una cosa al tercero beneficiado.

- * El fideicomisario favorecido podía reclamar lo que le fuera otorgado por medio de un *iudicium bonae fidei*, aplicándose al respecto lo establecido en los senadoconsultos Trebelliano y Pegasiano.

LAS HERENCIAS FIDEICOMISARIAS

Por medio del fideicomiso se podía otorgar, finalmente, la herencia a una persona distinta del heredero — en los casos en que, por ejemplo, el beneficiario carecía de capacidad (*testamenti factio passiva*) para recibirla por testamento.

- * Era necesario que el fideicomitente hiciera un testamento instituyendo un heredero —*heres fiduciarius*—, quien no recibirla la herencia, puesto que una vez percibida se le encargaba la transmitiera a otro denominado *fideicommissarius*.
- * La forma que revestía este procedimiento era la siguiente: "Ticio, sé heredero"; a lo cual se agregaba: "Te ruego, Ticio, y te pido, que tan pronto como aceptes mi herencia se la devuelvas y restituyas a Cayo Seyo".
- * La transmisión de la herencia por parte del heredero fiduciario al fideicomisario presentaba ciertas complicaciones. Se hacía por medio de una *mancipatio* simbólica —*nummo uno*—, por la que se transmitía el patrimonio. Pero restaba el problema de las acciones en favor —por los créditos— y en contra —por las deudas— de la herencia, para lo cual se agregaban las *stipulationes* usuales en la compraventa de una herencia.
- * Por medio de ellas, el heredero fiduciario se hacía prometer que por cualquier acción que se le dirigiera por una deuda de la herencia, sería defendido y desinteresado por el fideicomisario. A su vez, éste se hacía prometer que por las acciones por créditos de la herencia, podría actuar —a título de *cognitor* o de *procurator*—, quedándose con el provecho obtenido.
- * En cambio, si se trataba del fideicomiso de una parte de la herencia o de un fideicomiso particular, las *stipulationes* empleadas eran las

denominadas *partis et pro parte*, ya que aquel heredero fiduciario se lo asimilaba al *legatarius partarius* (legatario parciario).

- * Las partes se daban mutuamente *cautiones* (garantías) acerca del cumplimiento de estas *stipulationes*.
- * Sin embargo, esta forma de transmisión —al margen de las complicaciones que originaba— podía ser peligrosa en caso de insolvencia por parte del heredero fiduciario.

I. Se estableció entonces, por medio del senadoconsulto Trebelliano (año 56 d.C.), un sistema más simple. Cuando se realizaba una herencia fideicomisaria, se entendía —sin necesidad de la *mancipatio* ni de las *stipulationes*— que el fideicomisario ocupaba directamente el lugar del heredero (*heredis loco*), de tal modo que las acciones de la herencia les eran concedidas a su persona bajo la forma de *actiones utiles*.

II. Pero sucedió acá un problema semejante al ocurrido en materia de legados. Aquellos que debían transmitir la herencia —herederos fiduciarios— abandonando el criterio tradicional de la *fides* respecto del testador, y considerando que cada recibían, rehusaban aceptar la herencia, por lo que los fideicomisos caían incumplidos.

Se estableció, en consecuencia, por medio de un senadoconsulto Pegasiano (entre el 69 y el 79 d.C.), que el heredero que aceptara la herencia podía retener hasta una cuarta parte —a semejanza de lo dispuesto por la *lex Falcidia*—, con lo que se aseguraba un margen de interés para el *heres fiduciarius*. Esta porción será denominada *quarta Pegasiana*.

- * El sistema determinado por el senadoconsulto Pegasiano era un tanto complicado, por cuanto en parte parecía volver al sistema anterior del senadoconsulto Trebelliano. Brevemente, las situaciones que se presentaban eran las siguientes.
 - (A) Si el fideicomiso era parcial —es decir, que no llegaba a las tres cuartas partes de la herencia—, se aplicaba directamente el senadoconsulto Trebelliano.
 - (B) Si el fideicomiso era total o por una parte mayor a las tres cuartas partes de la herencia, se aplicaba el senadoconsulto Pegasiano. Si el heredero fiduciario se reservaba la cuarta parte, debía concertar con el otro *stipulationes* —como ocurría en la época anterior—, pero por tener el fideicomisario sólo las tres cuartas partes eran las *stipulationes* del tipo *partis et pro parte* —en la parte y por la parte— ya que era asimilado al legatario parciario (*legatarius partarius*).

114

504 1

113

Si en cambio no reclamaba la cuarta parte, entonces había que celebrar las *stipulationes* por el todo, como un sucesor universal.

(C) El heredero fiduciario que se negase a aceptar la herencia —después del senadoconsulto Pegasiano— podía ser obligado por el pretor a recibirla.

III. Justiniano simplificará todas estas formas, conservando lo esencial del senadoconsulto Pegasiano, que él interpretó era el derecho a la cuarta parte, y el constreñimiento por el pretor hacia el heredero que no quisiera aceptar la herencia. Para el resto, funcionaba directamente el senadoconsulto Trebelliano, de tal modo que las *stipulationes* se las entendía tácitamente incorporadas; y en caso de quedar parte para el heredero y parte para el fideicomisario, las acciones eran divididas a prorrata.

LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE

I. La donación *mortis causa* era realizada cuando una persona tenía un mal grave, como enfermedades, guerras, saqueos. El beneficiado se comprometía, por un acto de *fiducia*, a devolver la cosa si el donante se salvaba de dichos peligros, o si el beneficiario lo sobrevivía.

II. Más tarde, a comienzos del Imperio, podía adoptar esta otra forma: el donante realizaba el acto de la donación, pero sujetándolo a la condición suspensiva de su muerte. Si ésta acontecía, entonces el donatario podía hacer efectiva la donación.

III. Estas donaciones *mortis causa*, si bien son extrañas a la herencia propiamente dicha, importan al heredero, por cuanto merman los bienes por recibir. Poco a poco fueron asimiladas al régimen de los legados.

* En primer término, fueron las leyes Furia y Voconia —limitativas de los legados— las que incluían en su régimen estas donaciones; lo mismo ocurrirá luego con las leyes caducarias de Augusto y la *lex Falcidia*.

* Justiniano completará la equiparación con los legados. A diferencia de otras donaciones, no le exigirá la *insinuatio* —fuese oral o escrita— ante el escribano, bastando la presencia de cinco testigos, como sucedía en los codicilos.

SUCESION AB INTESTATO

Tiene lugar siempre que por el *de cuius* no haya sido hecho testamento válido, o haya resultado nulo (*ruptum vel irritum*), o no haya sido aceptado por los herederos instituidos (*destitutum, desertum*).

* Este carácter prevaleciente de la sucesión testamentaria no parece haber existido en los tiempos arcaicos. Según modernas interpretaciones que se han visto a propósito del *testamentum calatis comitiis*, éste (A) se refería a la jefatura del grupo y no a una asignación individualista del patrimonio —que seguía siendo familiar—, o (B) tenía lugar como adopción de un extraño, sólo cuando no había un *suus* varón.

* En ambas hipótesis resulta que los *sui* —es decir, los que estaban bajo el inmediato poder del *pater*— lo sucedían automáticamente en la patrimonialidad de la familia, fuere que permanecieran unidos bajo el poder del *heres* nombrado testamentariamente (A) de entre ellos o (B) de afuera, fuere que permanecieran —no habiendo designación testamentaria— unidos en *consortium* o *ercto non cito*.

* De todos modos, cualquiera sea la interpretación, tradicional o moderna, es sintomático que en la ley de las XII tablas la palabra *heres* se refiere o al instituido por un testamento, o exclusivamente a los *sui*. De los otros llamados a suceder, la ley dice “que tengan para sí (*habento*) el patrimonio”. Es que en la concepción antigua romana, si bien el *pater* es el único titular de derechos, el patrimonio es familiar y, por lo tanto, los *sui* son algo así como copropietarios —no en el ejercicio actual, pero sí en expectativa y en el goce actual—, tal como queda patente a la muerte del *pater* con la constitución del *consortium*, que no sería sino la continuación de la precedente comunión doméstica. Paulo, siete u ocho siglos más tarde, todavía se hace eco de aquella concepción cuando, tratando de la sucesión *ab intestato* de los *sui*, dice que pareciera no haber, en realidad, herencia (“*nulla videtur hereditas*”), toda vez que los *sui* debían ser considerados “*vivo quoque parente quodammodo domini*” (“en cierto sentido, como dueños, aun en vida del padre”).

Entre todas las instituciones del Derecho Romano, la sucesión *ab intestato* es la que ha sufrido mayor transformación, pasando de un sistema arcaico con base en la agnación —de acuerdo con la concepción de grandes grupos parentales de estructura y funcionamiento político y de economía cerrada de autoabastecimiento— a otro —que ha llegado a las legislaciones modernas— con base en la cognación, es decir, en el parentesco

de la sangre y de la consecuente real convivencia en grupos familiares más chicos, organizados de acuerdo con la institución matrimonial y con la igualdad del hombre y la mujer.

La evolución de la sucesión *ab intestato* será analizada en etapas: la de la ley de las XII tablas; la del *ius civile* basado en la interpretación de aquélla; la del sistema de las *bonorum possessiones*; la de los senadoconsultos; la de las constituciones imperiales y la de las novelas 118 y 127 de Justiniano.

LA SUCESSION AB INTESTATO EN LAS XII TABLAS

Existe en ellas un texto que la alude directamente: "*Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento*".

Este texto es susceptible de traducciones distintas, que pueden, en su significado de fondo, ser referidas a dos interpretaciones: la tradicional, que es la que inspira el trabajo de los juristas romanos y el de los comentaristas medievales, y es la que conviene que el estudiante retenga fielmente; y otra reciente que debe considerarse —como se apunta a propósito del *testamentum calatis comitiis*— en función del carácter político de la familia, tanto la agnaticia como la *proprio iure*, del patrimonio familiar, y del carácter prevaleciente, en tiempos arcaicos, de los *status* y relaciones personales sobre las patrimoniales.

La traducción que corresponde a la interpretación tradicional sería más o menos la siguiente: "Si muere intestado y no hay *heredes sui*, que el patrimonio lo tenga para sí el agnado más próximo; si no hay agnado, que lo tengan los gentiles". El análisis de esta interpretación se hará inmediatamente, bajo el título de "La sucesión intestada en el *ius civile*".

- * La traducción que correspondería a la interpretación reciente sería más o menos la siguiente: "Si muere intestado, es decir que para él ningún *sui* es heredero, que el agnado más próximo tome para sí el patrimonio; si no hay agnado, que lo tomen los gentiles". Morir intestado, en esta interpretación, es no haber designado *calatis comitiis* a uno de los *sui* como *heres*, es decir, como continuador de su jefatura, en la

familia grande o agnaticia. En tal supuesto, el agnado o los agnados más próximos —los que estaban bajo su directo o inmediato poder: sus hermanos y sus descendientes— quedan con el patrimonio constituyendo un *consortium*. Con el tiempo, la posibilidad de separarse de éste por medio de una acción *eriscundae familiae* habría sido el modo institucional del tránsito de la familia grande o agnaticia a la *proprio iure*.

LA SUCESSION INTESTADA EN EL IUS CIVILE

Es la que resulta de la interpretación e integración que los jurisprudentes hicieron del fragmento arriba analizado y de algunas otras soluciones legales o doctrinarias.

I. Hay tres clases de sucesores: (A) los *heredes sui*; (B) los agnados y (C) los gentiles.

(A) *Heredes sui*. — Eran quienes estaban bajo la inmediata patria potestad o *manus* del *de cuius* y que inclusive alcanzaba a los póstumos que estuviesen en dicha condición: 1) sin distinción de sexo y con la condición de *iustae nuptiae*, los hijos y los nietos cuyo padre —hijo del *de cuius*— hubiera premuerto o sido emancipado; 2) los adrogados o adoptados como hijos y sus descendientes, en el caso de premuerte; 3) su mujer considerada *loco filiae* (en la condición de hija) y las nueras casadas con hijos premuertos si para una y otras había tenido lugar la *conventio in manum*.

Todos los *sui*, pues, sucedían, aun en desigual grado de parentesco, siempre que hubieran estado al momento de la muerte bajo el inmediato poder del *de cuius*. La proporción en la que sucedían los hijos era *per capita* (por cabeza); los descendientes de ellos sucedían *per stirpes* (por rama).

- * Los *sui heredes* sucedían automáticamente; no necesitaban aceptar, ni podían repudiar la herencia. La ley de las XII tablas ni siquiera los llamaban a la sucesión, sino que, en la interpretación tradicional, presuponian su ausencia para llamar a la clase sucesiva, la de los agnados. Es que como ya se ha visto, que la calidad de sucesores era, en los *sui*, innata, en razón de la comunión familiar. A los otros agnados se les podía quitar toda expectativa con simplemente testar, pero a los *sui* se debía expresamente desheredarlos, y si eran preteridos, se invalidaba el testamento.

(B) Agnados. — No habiendo *heredes sui*, ni actuales ni póstumo, el agnado o agnados del mismo grado más próximo suceden en proporciones *per capita* (por cabeza) y excluyen de la sucesión a los subsiguientes en grado: los hermanos, al tío y al sobrino; estos últimos, a los primos, etcétera. No hay (A) representación ni (B) sucesión en grado ni (C) en orden: si un único hermano moría, o sufría *capitis deminutio*, o no efectuaba adición de la herencia, ésta no iba (A) ni a sus hijos, ni a los hijos de otro hermano premuerto, (B) ni a un tío, (C) ni pasaba a los gentiles. Quedaba abierto el camino a la *in iure cessio hereditatis* o a la *usucapio pro herede*.

◊ La ley de las XII tablas no hacía distinción de sexos, pero los jurisperitos, por analogía con las restricciones de la *lex Voconia*, limitaron la sucesión de las agnadas al sólo caso de las hermanas por parte paterna —germanas y consanguíneas.

(C) Gentiles. — A falta de agnados sucedían, de un modo desconocido para nosotros, los gentiles, es decir toda la *gens*. De todos modos, esa sucesión, sin duda, había desaparecido, por la completa irrelevancia de los vínculos gentilicios, en los tiempos de Gayo (siglo II d.C.).

II. Este sistema de la sucesión *ab intestato*, llamado legítimo en razón de la ley de las XII tablas, era, como se ha visto, un *ius strictum* en cuanto que reconocía únicamente la agnación —estructuradora de la gran familia patriarcal—, y excluía de la herencia a los hijos emancipados; a los agnados que hubieran experimentado una *capitis deminutio*; al marido; a la mujer, si no estaba *in manu*; a todos los parientes por vía femenina, al extremo de no haber sucesión recíproca entre madre e hijos, a no ser que por la *conventio in manum* se hubiera establecido entre ellos vínculo agnaticio. Este régimen habría de resultar *iniquitates* (cosas no equitativas) en una sociedad cada vez más distinta de aquella gentilicia sobre cuyos intereses y valoraciones dicho régimen se había estructurado. El pretor remedió esas *iniquitates* concediendo la *bonorum possessio* a personas con vínculos cognaticios.

LA SUCESIÓN AB INTESTATO EN EL SISTEMA DE LAS BONORUM POSSESSIONES

El régimen de la sucesión *intestata* pretoriana consistió en una articulación jerarquizada de hipótesis, unas donde se consagraban los vínculos agnaticios del *ius civile* y otras en que se institucionalizaba la creciente relevancia de los cognaticios. Se fue, pues, constituyendo un determinado orden preferente de parientes, agnados y cognados, a quienes se les ofrecía la *bonorum possessio*, la que, a partir de Antonino Pío (mediados del siglo II d. C.), fue siempre *cum re**, es decir, protegida con denegaciones de acciones y con excepciones frente a la *petitio hereditatis* de herederos de mejor título de acuerdo con el *ius civile*.

Los llamados a solicitar la *bonorum possessio* debían hacerlo en el plazo de cien días, con excepción de los hijos, que tenían un año para reclamarla.

En la última etapa del derecho honorario, el Edicto* Perpetuo, el sistema de la *bonorum possessio* presenta cuatro categorías de parientes llamados en el orden que se señala líneas abajo y con la admisión de la sucesión de órdenes (*successio ordinum*), es decir que no presentándose los de la primera categoría quedaba abierto el campo para que se presentaran los de la segunda, y así sucesivamente: (A) *liberi*; (B) *legitimi*; (C) *cognati*; (D) *vir et uxor*.

(A) *Liberi*. — (Los libres [sometidos al inmediato poder del *pater*; designados así por contraposición a los esclavos]). Eran los descendientes sobre la base de generación y matrimonio, aunque no hubieran estado sometidos al *pater* en el momento de su deceso. La categoría comprendía a los *sui* del *ius civile* —incluidos, por cierto, los adoptados y las mujeres *in manu*— y a los descendientes emancipados, que, por tanto, no tenían ya con el *de cuius* vínculo agnaticio, pero sí, un innato y definitivo vínculo de cognación.

◊ El hijo adoptivo emancipado no puede reclamar la *bonorum possessio*, pues ya no es agnado y nunca fue cognado. Podrá, sí, reclamar como cognado la *bonorum possessio* del patrimonio de su *pater* original, es decir, de quien lo engendró en *iustae nuptiae*.

La manera de suceder era en el orden y en la proporción similar a la de los *sui* en el *ius civile*: *per capita* para el primer grado de parentesco y *per stirpes* y con representación para los subsiguientes.

- Un ejemplo: muere el *de cuius* dejando a su mujer *in manu*, un hijo y una hija; un hijo adoptivo; dos nietos, hijos de un hijo premuerto; tres nietos, hijos de un hijo emancipado, A; otro hijo emancipado, B. La proporción en que se otorgaban las *bonorum possessiones* era la siguiente: un séptimo para cada una de éstas cinco personas: la mujer, el hijo, la hija, el hijo adoptivo, el hijo emancipado B; un séptimo para los dos nietos en representación de su padre premuerto; la mitad de un séptimo para el hijo emancipado A y la otra mitad para sus tres hijos que habían quedado bajo la patria potestad de su abuelo, el *de cuius*. Esta última fue la solución propuesta por Juliano para esa curiosa hipótesis en la que, según el *ius civile*, los nietos debían suceder, por representación, en el total de la cuota, y, según el sistema pretoriano, el hijo emancipado podía reclamar la *bonorum possessio* de toda la cuota.
- Otra situación chocante consistió en la desigualdad resultante de que, en tanto todo lo adquirido por los *sui* había ido a integrar el patrimonio del *de cuius*, en cambio, lo adquirido por el emancipado, precisamente desde la emancipación, había ido a constituir su patrimonio individual: la solución equitativa fue exigirle a este último que llevara a colación (*collatio* °) en la sucesión ese patrimonio adquirido hasta la muerte del *de cuius*.

(B) *Legitimi*. — No presentándose *liberi* a reclamar la *bonorum possessio*, el pretor la concedía a los designados en segundo lugar, los *legitimi*, llamados así por recibir su título de la ley de las XII tablas. Como los *sui* de ésta ya estaban incluidos entre los *liberi* y los *gentiles* habían dejado de suceder, sólo integraban esta categoría los agnados. Sucedian según grado de proximidad de parentesco tal como ocurría en los agnados del sistema del *ius civile*. No había, pues, sucesión en grados ni representación.

(C) *Cognati*. — Son los unidos al *de cuius* por vínculos de cognación, es decir, sobre la base de generaciones legítimas —concebidas en *iustae nuptiae*— por parte de varones o mujeres, y aun con base en generación ilegítima por parte de mujer. A la cognación se le reconocía relevancia sólo hasta un sexto grado de parentesco y hasta un séptimo si se trataba de los nacidos o nacidas de un sobrino o sobrina (*sobrino sobrinave nati*

et natae). Podían, pues, entre otros, reclamar la *bonorum possessio* como cognados: el padre y los hermanos de un *de cuius* emancipado, la madre y abuelos maternos de hijos legítimos o ilegítimos, los póstumos cognados, las mujeres excluidas por extensión de la *lex Voconia*, y todos los agnados —siempre hasta los grados sexto y séptimo—, aun los adoptados, pues la jurisprudencia y el pretor extendieron hasta la adopción la causal de cognación.

El llamado se hacía al cognado de grado más próximo y con exclusión de los otros, como en la categoría de los *legitimi*, pero con la importantísima diferencia de que el pretor admitía la sucesión en grado (*successio graduum*), es decir, que si no se presentaban cognados de un primer grado, la *bonorum possessio* quedaba a disposición de los del grado consecuente, y así sucesivamente. Si había varios cognados de un mismo grado, la *bonorum possessio* era otorgada *per capita*, es decir, por partes iguales.

(D) *Vir et uxor*. — Con este último llamado el pretor estableció un recíproco derecho de sucesión entre marido y mujer, sobre la base de las *iustae nuptiae*, pero independientemente de la *conventio in manum*.

LA SUCESION AB INTESTATO EN LOS SENADOCONSULTOS

Cuando se cristaliza el derecho honorario en el Edicto Perpetuo, la reforma de la sucesión *ab intestato* sigue a través de los senadoconsultos y las constituciones imperiales siempre en el sentido de hacer prevalecer los vínculos de sangre y remediar las *iniquitates* del sistema primitivo.

Los senadoconsultos consagran la sucesión recíproca entre madre e hijos e institucionalizan, así, en el plano del *ius civile*, los vínculos cognaticios, hasta ahora sólo amparados en el *ius honorarium*.

116

504 1

115

El senadoconsulto Tertuliano, de la época de Adriano, reconoció a la madre que tuviera el *ius liberorum** la sucesión de los hijos, legítimos o extramatrimoniales, que hubieran muerto intestados sin dejar *liberi*, ni padre manumisor, ni hermanos consanguíneos. Con la madre concurrían por la mitad las hermanas consanguíneas del *de cuius*.

Por el senadoconsulto Orficiano (178 d. C.) se atribuyó a los hijos legítimos o ilegítimos (*iusti aut vulgo concepti*) la herencia civil de la madre, con preferencia a los consanguíneos y a los agnados de la *de cuius*.

En ambos senadoconsultos se le daba, pues, condición de herederos a personas que no formaban parte de la familia civil.

LA SUCESSION INTESADA EN LAS CONSTITUCIONES IMPERIALES

La legislación posclásica tiende a liberar a la madre de la condición de tener el *ius liberorum* para suceder al hijo: Constantino le reconoce un tercio a la madre sin ese *ius*; Teodosio y Valentino dos tercios; con Justiniano queda libre de aquella condición.

Otra tendencia fue el incremento de la relevancia de la cognación. Valentino y Teodosio extendieron el principio del senadoconsulto Orficiano a los otros ascendientes por línea femenina, y Anastasio dispuso que podían sucederse entre sí hermanos emancipados junto con los no emancipados, aunque por una cuota menor que la de éstos. De ese modo, la cognación entró en el *ius civile* a ser considerada en la línea colateral, en tanto hasta ese momento sólo lo era en la de los descendientes. La diferencia en la cuota fue abolida por Justiniano.

Otras numerosas medidas legislativas tendían a solucionar en forma fragmentaria casos e inconvenientes sin una labor generalizadora. El complejo y no siempre concordante sistema que resultó se halla todavía en la compilación justiniana.

Pero dos constituciones nuevas iban a establecer un sistema unitario y completo de la sucesión *ab intestato*, en el que se conjugaba el *ius civile* y el *ius honorarium*.

LA SUCESSION AB INTESTATO EN LAS NOVELAS 118 Y 127

En este régimen se consagra definitivamente el vínculo de parentesco cognativo; la parentela adoptiva sólo se equipara a la de la sangre si está establecida en una *adoptio plena*, si no, sólo da derecho a la delación del hijo a la sucesión del padre adoptivo, y no viceversa.

La tradicional estructura de la familia romana con un único titular de derechos patrimoniales, el *pater*, sufrirá además otro golpe concluyente: quedará reconocida al *filiusfamilias* la plena capacidad de ser sucedido *ab intestato*, sin que sus bienes vayan —como había ocurrido hasta entonces— *iure peculii* (por condición jurídica de peculio *) al patrimonio del *paterfamilias*.

El *filiusfamilias* quedaba equiparado en este importante capítulo a los *sui iuris*.

Quedan establecidas cuatro clases de sucesores con *successio graduum et ordinum* (sucesión de grados y clases): en cada una es llamado el pariente de grado más próximo y por su falta o renuncia se pasa al grado sucesivo; sólo ante la falta de parientes de una clase se pasa a la siguiente.

Descendientes. — Son herederos todos los descendientes, con prescindencia de que hayan estado bajo la patria potestad o de cualquier consideración de sexo y de limitación de grado. Suceden, pues, *per capita* los hijos legítimos, legitimados y adoptivos —y, con respecto a la madre, también los extramatrimoniales—. Los descendientes de un hijo premuerto heredan por representación y *per stirpes*, es decir, dividiéndose la cuota que hubiera correspondido a ese hijo.

- Recuérdese que si el *de cuius* estaba bajo la patria potestad de su *pater*, a aquél le correspondía durante su vida el usufructo de la herencia, aunque la nuda propiedad se hallase distribuida entre los descendientes de aquél.

Ascendientes, hermanos o hermanas germanos y sus descendientes. — Si sólo hay ascendientes, suceden por líneas, es decir, concurren por mitades los paternos y maternos de un mismo grado, el más próximo. Si en ese grado sólo hay ascendientes de una sola línea —la paterna o la materna—, ellos heredan todo, pues, como no hay representación, quedan excluidos los ascendientes de la otra línea que pudieren existir en un grado siguiente.

Si concurren con ascendientes los germanos —hermanos o hermanas del mismo padre—, suceden todos *per capita*, es decir, por la misma cuota. Si concurren descendientes de hermanos germanos premuertos, lo hacen *per stirpes*, es decir, dividiéndose la cuota que les hubiera correspondido a aquéllos.

- Así, por ejemplo, si el *de cuius* sin descendientes deja vivos: (A) a su madre y a los dos abuelos paternos; hereda sólo la madre; (B) a un abuelo paterno y los dos maternos, aquél hereda una mitad y éstos se dividen la otra; (C) a un abuelo materno, dos hermanos germanos y tres sobrinos, hijos de un hermano germano premuerto, heredan los primeros un cuarto de la herencia cada uno, y los sobrinos se reparten el cuarto restante.

Hermanos y hermanas consanguíneos —del mismo padre— o uterinos —de la misma madre. — Suceden *per capita*; si premueren, suceden *per stirpes* sus hijos, pero no los ulteriores descendientes.

Cógnados colaterales. — A falta de sucesores de las otras categorías, suceden *per capita* los del grado más próximo, con exclusión de los demás, es decir sin representación.

Las novelas no indican si la limitación al sexto y séptimo grado —que está en la compilación y que venía desde la *bonorum possessio* de los *cognati* —queda o no derogada.

- El cónyuge supérstite no fue aludido en las novelas y por lo tanto quedaba vigente la *bonorum possessio unde vir et uxor*. Justiniano había, por lo demás, dispuesto que la viuda pobre tuviera derecho a una cuota igual a la de sus hijos —limitada a un cuarto y a 100 libras de oro— del patrimonio de su difunto esposo *locuples* (rico). Esa cuota era sólo de usufructo si concurría con hijos propios.

- Ante la falta de sucesores *ab intestato*, el fisco reivindica la herencia vacante: la de eclesiásticos va a la Iglesia o al convento; la de los curiones, a la curia; la de los soldados, a la respectiva legión; la de ciertos profesionales, a la respectiva corporación, etcétera.

LA SUCESION INTESTADA DEL LIBERTO

Hay un régimen distinto porque distintos son los *status* y circunstancias: el liberto sólo al alcanzar la libertad podía comenzar a tener vínculos de parentesco, no tenía *gens* ni agnados que no fueran sus descendientes *in patria potestate* —posteriores, por cierto, a su manumisión—; además, su vínculo con el patrono suponía derechos sucesorios de éste y sus parientes. La evolución de la sucesión *ab intestato* —que en el caso del ingenuo se caracterizó por la paulatina relevancia de los vínculos cognaticios y su carácter prevaleciente final—, en el caso del liberto tendió a dar preferente colocación a los parientes por sangre de éste, en correlativa contraposición con el *patronus* y sus parientes agnaticios y cognaticios.

Pero, aun en la etapa final, la justiniana, no desaparece el derecho del patrono, que prevalece todavía sobre los colaterales y el cónyuge supérstite del liberto.

I. En la ley de las XII tablas el orden sucesorio era:

- 1) Los *sui* del liberto;
- 2) el *patronus* o la *patrona*;
- 3) los *sui* del *patronus*, aunque éste los hubiera desheredado;
- 4) los agnados colaterales del *patronus* o *patrona*;
- 5) los gentiles del *patronus* o *patrona*.

II. El orden elaborado por el pretor para el otorgamiento de las *bonorum possessiones* dio, por cierto, cabida a los vínculos cognaticios del liberto.

- 1) *Liberi*: descendientes del liberto. Si sólo hay hijos adoptivos o mujer *in manu*, concurren por mitades con el *patronus* sus hijos varones.

117

504.1

116

- 2) *Legitimi*: de acuerdo con la ley de las XII tablas son —aparte de los *sui* ya figurantes en el primer llamado— el *patronus*, sus *sui*, sus agnados colaterales y sus gentiles.
- 3) *Cognati*: parientes por sangre del *de cuius*.
- 4) *Familia patroni*: los miembros de la familia civil del patrono y éste, cuando por una *capitis deminutio minima* no hubieran entrado en la categoría de los *legitimi*.
- 5) *Patronus* y *patrona* del *patronus* o *patrona* —si éstos eran, a su vez, libertos—, y sus *liberi* y ascendientes.
- 6) *Vir et uxor*: el cónyuge del liberto o liberta *de cuius*.
- 7) *Cognati manumissoris*: los parientes cognados del *patronus* o *patrona*.

III. En el derecho justiniano se destaca el reconocimiento —debido al cristianismo— de la *servilis cognatio* (parentesco de la sangre sucedido durante la esclavitud).

- 1) Descendientes del liberto.
- 2) El *patronus*, sus hijos y colaterales hasta el quinto grado; a éstos son preferidos los padres y hermanos del liberto si, a su muerte, han dejado ya de ser esclavos.
- 3) Colaterales del liberto hasta el quinto grado.
- 4) Cónyuge supérstite.



INDICE ANALITICO

(El número en negrita indica la página donde se encuentra la referencia más específica.)

- | | |
|---|--|
| abandono, 196, 208 | actio in rem verso, 367 |
| abrogatio, 35, 38 | actio institoria, 367 |
| acceptilatio, 329, 384, 388 | actio iudicati, 176-178, 324 |
| accesión, 147, 199 209-210 | actio locati, 298 |
| acción, 117, 165, 166, 182, 186, 328 | actio mandati contraria, 301-302, 331, 337 |
| accusatio suspecti tutoris, 389 | actio negatoria, 219, 222-223 |
| acrecimiento, 408-409 | actio Pauliana, 323-324 |
| actio, acciones: ver acción y formulae | actio per conditionem, 172 |
| actio ad exhibendum, 209, 210 | actio per iudicis arbitrive postulationem, 171-172 |
| actio ad supplendam legitimam, 434 | actio praescriptis verbis, 307 |
| actio aquae pluviae arcendae, 223-224 | actio pro socio, 300 |
| actio arbitraria, 185, 413 | actio Publiciana, 218, 221-222, 225 |
| actio auctoritatis, 293 | actio quod iussu, 367 |
| actio bonae fidei, 184, 258, 284, 298, 300, 340, 384 | actio quod motus causa, 163 |
| actio certae creditae pecuniae, 244 | actio rei uxoriae, 382 |
| actio communi dividundo, 184, 206, 239, 261, 300 | actio sacramento, 171 |
| actio conducti, 298 | actio Serviana, 248, 326-327 |
| actio confessoria, 240 | actio stricti iuris, 184 |
| actio de arboribus succisis, 269 | actio tributaria, 367 |
| actio de eo quod certo loco, 333 | actio venditi, 293 |
| actio de pastu pecoris, 269 | actio vi bonorum raptorum, 268 |
| actio de peculio, 365, 367 | actiones adiecticiae qualitatis, 154, 257, 366-367 |
| actio de rationibus distrahendis, 389 | actiones (legis), 75, 168, 324 |
| actio doli mali, 162-163, 259 | acto, 140-143 |
| actio empti, 292 | acueducto, 238 |
| actio exercitoria, 367 | addicti, 115 |
| actio ex stipulatu, 285, 382 | addictio (in diem), 147, 148, 295 |
| actio familiae erciscundae, 184, 239, 261, 346, 353, 426, 449 | adir: ver aditio |
| actio finium regendorum, 184, 223 | aditio (hereditatis), 405, 440 |
| actio furti, 185, 266-268 | adiudicatio, 180, 184, 205, 218 |
| actio iniuriarum, 134, 270-271, 397 | adopción, 115, 216, 354, 359-361 |
| | adrogación, 36, 130, 257, 358-359, 393, 417 |
| | adstipulator, 286, 331 |
| | adulterium, 374, 375 |

- aequitas, 10, 11, 83, 145, 154, 182, 259
 aequum et bonum, 10
 aerarium, 124
 aestimatum, 308
 afinidad, 372, 373, 377
 ager decumanus, 45-46
 ager publicus, 34, 35, 45, 45-46, 202, 203, 229, 230, 231
 ager stipendiarius, 45-46
 ager tributarius, 45-46
 ager vectigalis, 45-46, 245
 ager viritanus, 45-46
 agnación, 347, 396, 447
 alieni iuris, 120, 358, 359
 aluvio, 209
 alveus derelictus, 209
 anexión, 42-44
 animus, 230, 231
 antichresis, 250
 anulabilidad, 159-164
 apelación, 191
 apud iudicem, 168-170
 arras, 290, 377
 auctoratus, 115
 auctoritas, 32, 33, 42, 49, 51, 84, 85, 159, 191, 212-213, 216, 231, 257, 331, 371, 387, 390, 392
 augures, 24
 avulsio, 209
- bárbaros 52, 54, 55, 57, 94-95
 beneficium cedendarum actionum, 277
 beneficium competentiae, 324, 325, 327, 328, 332, 373, 383, 397
 beneficium divisionis, 276
 beneficium excussionis, 276
 beneficium inventarii, 412
 bona, 114
 bonorum cessio, 325, 328, 332
 bonorum distractio, 327
 bonorum emptor, 326-327, 340
 bonorum possessio, 83, 155, 222, 398-401, 431, 451-453
 bonorum possesores sine secundum, contra tabulas, 400, 410
 bonorum sectio, 327
 bonorum separatio, 404, 411
- bonorum venditio, 131, 178, 181, 192, 322, 325-327, 333, 340, 403, 405
 burocracia, 16, 59
- capacidad, 103-105, 385-392
 capitis deminutio, 107, 118, 257, 339, 359, 361, 364, 428
 caso fortuito, 262, 293, 316-317, 320
 causa (iusta), 217, 285, 290, 300, 313
 cautio, 285, 387
 cautio damni infecti, 186, 223
 censor, 38
 cessio (in iure), 135, 202, 216-217, 240, 407
 chirographa, 289
 ciudad estado, 7, 27, 33
 ciudad quiritaria, 17
 cives optimo iure, 31, 45, 117-118
 civitas, 17, 22, 24-25, 29, 33, 67, 69, 125, 353
 clientes, 22
 codex: ver código
 Codex Theodosianus, 88-89
 codicilo, 421-422
 código, 82, 89, 90, 91, 121
 código civil argentino, 100
 Código de Justiniano, 90
 coemptio, 361, 363, 390
 cognación, 347, 396, 447, 454
 cognati, 452
 cognitio extraordinaria, 83, 168, 188-192, 302, 341, 443
 cognitor, 176, 278, 444
 colegialidad, 36, 206
 colonato, 59, 115
 collatio, 409-411
 collegia, 125-126
 comicio centuriado, 28
 comitatus calatis, 352, 416
 commercium, 132, 441
 commissoria (lex), 295
 commixtio, 207, 211
 Common Law, 98
 comodato, 303-304
 compensación, 340-341, 384
 compilación justiniana, 7, 89-92

- compraventa, 215, 290-296
 compromiso, 312
 concilio, 29, 43
 concubinato, 374-376
 condemnatio, 176, 177, 183, 206, 279, 319, 367
 condición, 147-151
 conditio causa data causa non secuta, 274
 conditio certae rei, 244
 conditio de eo quod certo loco, 333
 conditio ex lege, 274
 conditio furtiva, 268, 274
 conditio generalis, 274
 conditio indebiti, 258, 273, 274
 conditiones, 183, 274, 306
 conditio ob iniustam causam, 274
 conditio ob turpem causam, 274
 conditio sine causa, 274
 condominio, 199, 205-207, 273
 confarreatio, 26, 361, 363, 368
 confusión, 211, 240, 246, 339
 connubium, 29, 70, 72, 368, 369, 370-371, 373, 374, 375
 consensus, 142, 283, 371
 consignar, 321, 334
 consortium, 205-206, 273, 299, 353, 408, 447
 constitución, 31
 constituciones imperiales, 11, 86-87, 91, 93, 398
 constitutum, 155, 218
 cónsul, 21, 30, 40
 contio, 41
 contracto (quasi ex), 272-274, 408
 contrato, 281-283
 contratos litteris, 83, 287-289
 contubernium, 109
 convención, 281-283
 coposición, 234
 corpus, 230, 231
 corpus iuris, 9, 91-94, 99
 costumbre, 62, 88
 cretio, 404
 crimina, 255, 265
 cuestor, 40
 culpa, 318-320
 culpa lata, 304, 318
 curatela, 22, 390-392
- curator, 154, 390-392
 Curiana (causa), 156-157, 428
 curias, 23, 24, 41, 416
 cursus honorum, 29, 33, 39, 74
 custodia, 317
- damnum iniuria datum, 265, 268-269
 dare, 255, 263
 decemviri, 30
 decretum, 87, 398
 decretum repentinum, 81, 182
 decuriones, 45, 358
 dediticios (libertos), 52, 112, 113
 dediticios (peregrinos), 52, 119
 deditio noxae, 265, 363
 delegatio, 336-337
 delicta, 255, 265, 365
 delicto (quasi ex), 271-272, 311, 334
 demonstratio, 179
 denegatio (actionis), 175, 177
 depósito, 304-305
 derecho objetivo, 10, 81, 82
 derecho quiritarario, 18, 68
 derecho subjetivo, 10, 81, 82
 derelictae (res), 196, 213
 desheredación, 432
 detestatio sacrorum, 359
 diarquía, 51
 dictador, 30
 dictio (dotis), 286-287, 312, 334, 381
 diffarreatio, 363, 378
 Digesto, 91-93, 98, 101
 divortium, 377-379
 doctrina, 62
 dolo, 162-163, 317
 Dominado, 17, 54-55
 dominio bonitario: ver propiedad bonitaria
 dominium, 46-48, 199-200, 202, 229, 349
 dominus, 56, 57, 78, 108, 109, 110, 111, 112, 200, 222
 donación, 152, 158, 286, 308, 312-314, 332, 384, 385
 dote, 137, 286, 332, 381-384
 ductus, 238
 duoviri perduellionis, 25

118

504 1

117

edicto, 80-81, 87, 178, 187-188
 Edicto de Caracalla, 49, 52, 87, 119
 Edicto del Maximo, 59
 Edicto de Milán, 58
 Edicto de Tolerancia, 58
 Edicto Perpetuo, 87, 451
 edicto translaticio, 87, 187
 ediles, 29, 49
 ejecución, 170, 178, 192
 emancipación, 73, 115, 215, 354, 363-364
 emptio spei, rei speratae, 291
 emptor (familiae), 346, 418
 enfiteusis, 227, 230, 231, 245-246
 erectum non citum, 205-206, 299, 353
 error, 160-162, 273
 esclavitud, 107-114
 especificación, 207, 211
 estipulación: ver stipulatio
 estipulaciones pretorianas, 186, 223, 285
 etruscos, 20, 21, 23
 evicción, 146, 293, 332
 exceptio, 76, 112, 175, 179-180, 328
 exceptio doli mali, 162-163, 332, 341
 exceptio legis Cinciae, 313
 exceptio legis Plaetoria, 392
 exceptio non numeratae pecuniae, 289
 exceptio pacti conventi, 309, 342
 exceptio quod metus causa, 163
 extraneus (heres) 402, 404-405, 439
 extra ordinem: ver cognitio
 extraprocesales (rec), 80, 186-187
 facere, 255
 familia, 345-347
 familia agnaticia, 201, 202, 203, 349-353
 familia communi iure: ver familia agnaticia
 familiae emptor: ver emptor
 fas, 12
 feciales, 24
 ferruminatio, 210
 fianza, 275-277
 ficticias (acciones o fórmulas), 171, 181, 424, 429

fictio legis Corneliae, 108
 fideicomiso, 111, 152, 442-446
 fidelussio, 276
 fidepromissio, 261, 275
 fides, 80, 146, 174, 259
 fides (bona), 80, 156, 174, 175
 fiducia, 152, 154, 184, 248, 390, 418
 filiación, 357
 filius familias, 120, 231, 257, 265, 335, 347, 353, 357, 359, 363, 365, 366, 386, 430, 431, 455
 fiscus, 124
 flámines, 26
 foenus nauticum, 303
 formalismo, 66, 146
 fórmula, 174, 178-180, 218
 formulae conceptae in ius, in factum, 175, 180-182, 210, 271
 formulario (procedimiento), 167, 169, 173-178
 formula Rutiliana, 326
 fragmento de Gayo, 63-65, 73, 81
 fraude, 322
 frutos, 138, 212, 225
 fuerza mayor, 316-317
 fundaciones, 126
 fundos itálicos, 46, 52
 furiosus, 123, 169, 317, 390, 391, 436
 furtum, 209, 213, 266-268

genérica (cosa), 136, 316
 gens, 21-22, 201, 346, 348, 351
 gentiles, 22, 450
 gestio, 154, 184, 272-273, 300, 331, 388, 389
 Glossa Magna, 98
 Guerra Social, 16, 35

habitación, 197, 235, 244
 Haftung, 254, 329
 hecho, 140
 herede (usucapio pro): ver usucapio hereditatis
 heredero, 152, 397, 402-405, 427
 hereditas, 214, 397-398
 heredium, 201
 hipoteca, 247-251, 275, 322

honor, 33, 50, 52, 78, 122-123, 183, 386
 impedimentos 371-373
 impensas, 210, 220-221
 imperfecta (lex), 76, 313
 imperium, 21, 24, 25, 30, 37, 39, 40, 44, 45, 49, 82, 186
 impúberes, 121
 inaedificatio, 209
 infamia, 41, 122-123, 327
 infans, 169, 317, 388
 ingenuidad, 112
 infectio (manus), 115, 170, 172-173, 256, 324
 iniuria, 265, 270-271
 innominados (contratos) 306-308, 342
 Instituciones de Justiniano, 93
 intentio, 179, 180, 182, 183
 intercessio, 27, 38
 interdictio aqual et ignis, 118
 interdictos, 134, 187, 232-234, 296
 interdictum quod vi aut clam, 224
 interdictum quorum bonorum, 415
 interpolaciones, 91
 interrex, 42
 intuitu personae, 161
 iter, 238
 iudicium, 166, 187
 iura, 14, 88, 89, 90, 93, 235
 iura in re aliena, 149, 196-197, 235
 iure (in), 168-169, 173
 iurisdictio, 11, 29, 37, 40, 44, 67, 72, 73, 82, 88, 166, 174, 175, 189
 iurisprudencia, 13, 60, 62, 67
 ius, 10-11, 68, 215
 ius abstinendi, 403
 ius actionis, 117
 ius agendi cum populo, 37
 ius agendi cum senatu, 37, 41
 ius civile, 11, 12, 72, 74, 75, 80, 88, 96, 174, 181, 239, 258, 281, 290, 309, 401, 455
 ius commercii, 111, 132, 207, 441
 ius connubii, 111
 ius distrahendi, 250
 ius exponendi, 356, 357, 364

ius gentium, 11, 12, 18, 46, 73, 82, 87, 88, 119, 174, 207, 290
 ius honorarium, 14, 74, 75, 78, 80, 87, 401, 455
 ius honorum, 112
 ius inferendi, 133
 ius legitimum, 11
 ius liberorum, 390, 454
 ius naturale, 11, 12, 207
 ius novum, 83, 88
 ius noxae dandi, 365
 ius Papirianum, 69
 ius praetorium: ver ius honorarium
 ius privatum, 11-12
 ius prohibendi, 206, 223
 ius provocationis, 117
 ius publice respondendi, 84-85
 ius publicum, 11, 112
 ius sepulcri, 133
 ius suffragii, 112
 ius tollendi, 210
 ius variandi, 263
 ius vendendi, 356
 ius vitae ac necis, 356
 iustitia, 13

latina (condición), 35, 52, 118-119
 latini coloniarii, 119, 424
 latinos, 118, 424
 latinos junianos, 52, 112-113, 119, 424
 laudemio, 246
 legado, 110, 274, 436-439
 legatum per damnationem, 260, 329, 437-438
 legatum per vindicationem, 437
 leges, 88, 89, 93
 leges regiae, 69
 legitima, 416, 432-436
 legitimación, 358, 375
 legitimi, 452
 ley, 62, 73-76
 Ley de Citas, 89-90
 leyes caducarias, 425
 leyes romano-bárbaras, 89, 96-97
 lex Aebutia, 168, 174
 lex Aelia Sentia, 112, 117

lex Apuleia, 275
 lex Aquilia, 76, 185, 268-269, 286
 lex Atilia, 387, 390
 lex Calpurnia, 172
 lex Cannuleia, 29, 69, 70, 76
 lex Cicereia, 276
 lex Cornelia de iniuriis, 270
 lex curiata de imperio, 24
 lex XII Tabularum, 69-73
 lex Falcidia, 420, 434, 442, 445, 446
 lex Fufia Caninia, 112
 lex Furia testamentaria, 441, 446
 lex Hortensia, 32, 77
 lex Iulia de adulteriis, 373, 374, 382
 lex Iulia de fundo dotali, 381
 lex Iulia de maritandis ordinibus, 425
 lex Iulia et Titia, 387, 390
 lex Iulia iudiciorum privatorum, 168, 175
 lex Iulia municipalis, 45
 lex Minicia, 116
 lex Ovinia, 41
 lex Papia Poppaea, 404, 425, 440
 lex Plaetoria, 121, 390, 392
 lex Poetilia Papiria, 69, 250
 lex Rhodia de iactu, 80, 298
 lex Romana Burgundionum, 97, 419
 lex Scribonia, 228, 239
 lex Valeria Horatia, 29
 lex Voconia, 425, 442, 446
 liberi (unde), 431, 451-452
 libertatis (status), 107, 116, 169
 libertos, 52, 112-113, 457, 458
 libertos dediticios, 52, 113
 libram (per aes et), 215-216, 255, 256, 413
 libripens, 215
 limes, 59
 limitati (fundus), 208, 209
 litis aestimatio, 185, 218
 litis contestatio, 177, 190, 191, 257, 278, 318, 387, 414
 litis crescentia, 324
 litis denuntiatio, 190
 locación, 296-298

locatio-conductio rei, operarum, operis, 296-298

magister bonorum, 326
 magister populi, 30,
 maleficia, 265
 mancipatio, 72, 109, 114, 135, 181, 206, 215-216, 240, 293, 361, 363
 mancipi (in causa), 114-115, 120, 265, 355, 356, 360, 363
 mancipium, 73, 135, 196, 200, 201, 202, 216, 228, 229, 354-355
 mandato, 154, 300-302, 331
 manum (conventio in manum), 338, 347, 361-363, 373, 393
 manumisión, 110-111, 146, 424
 manus, 130, 228, 361-362, 379, 402, 431
 matrimonio, 367-370
 mentecaptus, 123, 391
 menores, 121-122, 186, 250, 392, 433
 misiones in possessionem, 186, 250, 325
 modus, 126, 152
 mora, 314, 320-322
 mores maiorum, 67, 72, 73, 77, 228
 Muciana cautio, 150
 Muciana praesumptio, 313, 373, 380
 muerte, 106
 munera, 59, 117, 358
 municipium, 44, 125
 mutuo, 138, 302-303

nacimiento, 105
 natalium restitutio, 112
 naturales (elementos), 146, 293
 naturales (obligaciones), 109, 257-258
 naturalis, 207, 226, 257
 necesarias (mejoras), 220-221, 383
 nefas, 12
 negocio, 139
 negocio abstracto, 145, 285
 negocios (interpretación de los), 155-157, 282
 nexum, 115, 254, 256, 281, 329
 nomen, 22, 118

nomina transcripticia, 287-289
 novación, 277, 279, 288, 334-338
 novatio: ver novación
 Novelas, 91, 93, 455, 456, 457
 noxal (abandono), 109, 356-357, 363
 nulidad, 159
 nuncupatio, 216, 418
 nuptiae (iustae), 107, 116, 117, 347, 357, 373, 375

obligatio, 254-256
 obsequium, 114
 ocupación, 207, 208, 209
 oneris ferendi, 237, 239, 262
 operae, 114
 operae servorum, 197, 235, 245
 operis novi nuntiatio, 223

pacto, 363-314
 pacto legitimo, 312-314, 381
 pactum displicentiae, 148, 295
 pago, 330-334
 Pandectística, 7, 101, 139, 155
 Paráfrasis de Teófilo, 95
 parapherna, 380
 parentesco, 348
 paterfamilias, 24, 64, 69, 76, 346, 364
 patres: plural de paterfamilias
 patricios, 16, 28-29
 patrimonio, 130-131, 193
 patronato, 112, 114
 patronus, 22
 peculio, 137, 181, 257, 354, 359, 365-366, 410
 peculio adventicio, 243, 366
 peculio castrense, 365
 pecunia, 131, 303
 perceptio, 138, 212
 peregrinos, 45, 118, 119
 peregrinos dediticios, 52, 119
 permutatio, 138, 212
 persona, 104
 personalidad de las leyes, 65, 96, 370
 personas jurídicas, 123-127

petendo (pactum de non), 147, 309, 330
 petitio (hereditatis), 413-414
 pictura, 210
 pignoris capio, 167, 172, 324
 pignoris conventio, 249
 pignoris datio, 249
 pignus, 226, 230, 248-251, 266, 275, 305
 plantatio, 209
 plebeyos, 27, 28-29
 plebiscito, 29, 32
 plumbatura, 210
 polis, 27, 33, 56, 70
 pontifices, 26, 65
 populus, 27, 30, 31, 33, 35, 51, 124
 posesión, 46, 135, 214, 224-234
 possessio ad interdicta, 220, 226
 possessio ad usucapionem, 228, 248
 possessio (bonorum): ver bonorum
 possessio
 possessio iuris, 235
 possessio (quasi), 234, 240
 possessio status, 235
 postliminium, 108, 226, 368, 373, 424, 429
 postumos, 402, 424
 potestad (patria), 355
 praescriptio, 179, 185, 307, 342, 343, 414
 praescriptio longissimi temporis, 215
 praescriptio longi temporis, 155, 185, 214-215, 240, 241
 praestare, 255
 praetor, 29, 30, 40, 63, 78-82, 121, 122, 131, 143, 145, 159, 173, 221, 222, 223, 245, 247, 248, 256, 258, 268, 269, 270, 271, 274, 281, 282, 284, 285, 295, 303, 309, 310, 313, 322, 325, 326, 327, 328, 333, 336, 340, 342, 365, 367, 387, 392, 418, 421, 443, 446, 450, 451, 453
 precario, 227, 230, 308
 prenda: ver pignus
 prescripción liberatoria, 342-343
 preterición, 428, 430-431
 pretor: ver praetor
 Princeps, 17, 41, 49, 78

118
 504 1

118

Principado, 17, 37, 48-51
 procesales (recursos), 80, 175
 Proculeyanos, 83, 121, 211
 procurator, 155, 176, 278, 279, 331, 444
 pródigo, 166, 391
 promagistratura, 34, 36, 38, 45, 50
 promissio iurata liberti, 114, 287
 promissio dotis, 287, 312, 381
 propiedad, 198-205, 230
 propiedad bonitaria, 113, 181, 203, 221, 222, 225
 propiedad peregrina, 202
 propiedad provincial, 133, 202, 246
 provincia, 45
 provocatio, 37, 117
 proximus infantiae, 121, 317, 388
 proximus pubertati, 121, 388
 puberes, 121
 putativo (título), 214, 227

 quaestores parricidii, 25
 querela inofficiosae donationis, 436
 querela inofficiosi dotis, 436
 querela inofficiosi testamenti, 395, 420, 432-436
 quirites, 16, 68

 rapina 265, 268
 re (cum), 399, 431, 451
 recepta, 310-311
 redemptus ab hostibus, 116
 regla Catoniana, 441
 reivindicación, 111, 219-221, 225
 religiosus, 109, 133, 204
 remancipatio, 363, 378
 remisión, 324, 341-342
 renacimiento (del Derecho Romano), 97-98
 representación, 153-155, 176
 res, 129-130, 213, 302
 rescriptum, 86, 359
 reserva mental, 158
 res nullius, 208, 406
 res publica, 31-32
 restituciones, 220

restitutio (in integrum), 121, 159, 186, 322, 359, 380, 392
 retentiones, 383-384
 rex, 16
 rogatio, 43, 358
 romanitas, 116
 Roma Quadrata, 20

 Sabinianos, 85, 121, 211
 sabinos, 20
 sacer, 29, 167
 sacra, 22
 Schuld, 254, 329
 scriptura, 210
 seminatio, 209
 Senado, 24, 41-42
 senadoconsulto Macedoniano, 257, 303
 senadoconsulto Neroniano, 83, 438-439
 senadoconsulto Orficiano, 454
 senadoconsulto Pegasiano, 445-446
 senadoconsulto Tertuliano, 454
 senadoconsulto Trebelliano, 445-446
 senatusconsultum, 11, 42, 398
 sententia, 170, 178, 191-192
 separatio, 138, 212
 Septimontium, 20
 servidumbre, 197
 sociedad, 298, 300, 339
 socii, 35, 45, 48, 298
 solutio per aes et libram, 329
 sponsalia, 376-377
 sponsio, 172, 256, 275, 281, 284-286, 330, 334
 sponsor, 261
 spurii, 357
 status, 106-120
 stipulatio, 109, 256, 260, 277, 281, 284-285, 289, 293, 312, 330, 336, 337, 410, 445, 446
 stipulatio Aquiliana, 330, 338, 342
 stipulatio poenae, 147
 stuprum, 374
 substitución, 427-428
 substitución pupilar, 157, 428
 sucesión, 131, 326, 393-394

suffragium, 24, 30
 sui iuris, 11, 120, 202, 346, 353, 363, 364
 sujetos (transposición de), 175, 182, 326
 superficies, 197, 227, 230, 231, 234, 247
 suus (heres), 397, 402-403, 428, 449
 syngraphae, 289

 tempus, 214
 tenencia, 224, 296
 tesoro, 208
 testamenti factio activa, 108, 117, 423-424
 testamenti factio passiva, 117, 424-425
 testamento pretorio, 83, 399, 413
 testamentum calatis comitiis, 349, 352, 416-417, 448
 testamentum in procintu, 352, 416-417
 Tetrarquía, 55
 timocrático, 21, 24, 27, 31-32
 tinctura, 210
 tipicidad, 14, 67
 titulus, 213
 tradición, 130, 208, 217-218, 231, 290, 381
 traditio: ver tradición
 transactio, 308, 342
 transcripticia (nomina), 287-289, 334
 tria nomina, 117-118
 tribuni consulari potestate, 28
 tribunos de la plebe, 27, 38

tribus, 23
 trinoctium, 73, 229, 354, 362
 tutela, 22, 122, 273, 347, 385-390
 tutor, 154, 385-390

 uso, 197, 235, 244
 usucapio: ver usucapion
 usucapio hereditatis, 214, 229, 406-407, 413
 usucapion, 130, 135, 139, 181, 186, 212-215, 228, 326, 362, 406
 usufructo, 197, 235, 241-244
 usufructum (quasi), 243-244
 usus, 212, 228-229, 241, 362
 usus (furtum), 250, 266, 304
 útiles (mejoras) 383
 utilitas publica, 58, 81, 83
 uti possidetis, 233
 utrubi, 233
 uxor, 379, 380, 453

 vadimonium, 176
 venta "ad gustum", 148, 149, 295
 vía, 238
 vicios redhibitorios, 146, 294
 vindex, 169
 vindicatio, 196, 240
 violencia, 163-164
 vir, 453
 vocatio in ius, 169, 176
 voluntad, 143-144, 153-158
 voluntad (vicios de la) 160-164, 282
 voluptarias (mejoras), 221, 383
 vulgo concepti, 357

SUMARIO

CAPITULO I

NOCIONES PRELIMINARES

Concepto de Derecho Romano	7
Nociones fundamentales	10
Ius	10
Ius publicum-Ius privatum	11
Ius publicum	11
Ius privatum	11
Fas	12
Iustitia	13
Iurisprudencia	13
Aequitas	13
Caracteres del Derecho Romano	13
Períodos históricos	15
Propuesta para una división de la historia romana	17
Distintas propuestas de periodización del Derecho Romano	17

CAPITULO II

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES POLITICO-SOCIALES ROMANAS

La ciudad quiritaria	19
Los orígenes y los reges	19
La gens	21
Las tribus	23
Las curias y el comicio curiado	23

120

504 1

cho
cho
SAU
(A) et al

119

El senado	24
El rex	25
Colegios sacerdotales	26
La civitas patricia y la transición a la res publica	26
Civitas	26
Procesos que llevan a la estructuración de la res publica	27
Conflicto e integración patricio-plebeya	28
La formación del populus	30
Los herederos del imperium	30
Res publica	31
Caracteres del régimen constitucional de la res publica ..	31
Períodos de la res publica	32
Perfeccionamiento de la integración patricio-plebeya	32
Equilibrio funcional de la civitas	33
Preponderancia de la política imperialista	33
Crisis de la res publica	34
Guerras civiles	36
Organos de la res publica	37
La magistratura	37
Distintas magistratura	39
El Senado	41
Los comicios	42
Estructuración del ámbito hegemónico romano durante la res publica	44
Hegemonía en Italia	44
Hegemonía fuera de Italia	45
La condición del suelo	46
Principado	48
El sistema político del Principado	49
Los poderes del príncipe	49
Los órganos tradicionales	50
Naturaleza política del Principado	51
Evolución estructural del Imperio	51

Los grandes momentos históricos del Principado	52
El siglo de Augusto	52
Pax Romana	53
La crisis del siglo III	53
El Dominado	54
Reorganización del Imperio	55
Fisonomía y organización del poder	56
Estructura del Imperio	57
El cristianismo y el Imperio	57
Concepción totalitaria del estado	58
Los bárbaros y el ejército	59
División del Imperio	60

CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO ROMANO

Concepto de fuentes del derecho	61
La costumbre	62
Doctrina	62
Jurisprudencia	62
Ley	62
Derecho arcaico	64
Caracteres del derecho arcaico	64
(A) Conservatismo	64
(B) Preponderancia de los conceptos de poder y de status personal ..	64
(C) Sentido exclusivista del ordenamiento jurídico	65
(D) Originalidad	65
(E) Dinamismo	65
(F) Temprano deslinde entre lo jurídico y lo mágico religioso ..	65
(G) Formalismo	66
(H) Tendencia a la generalización y sistematización	66
Las mores maiorum y la disciplina pontifical	67
Legislación	67
Ley de las XII tablas	69

Derecho preclásico	73
Los sistemas estratificados del derecho preclásico	73
La labor doctrinaria de los jurisperitos	74
Períodos de la jurisprudencia preclásica	75
Legislación	75
Lex	75
Plebiscito	77
Senadoconsulto	77
La labor jurisdiccional	77
El pretor peregrino y el ius gentium	79
La fórmula y el edicto, pilares del ius honorarium	80
El Derecho Romano como un sistema de acciones	81
Derecho clásico	82
Caracteres	82
Universalismo	82
Decreciente formalismo	82
Decreciente rigidez	83
Paulatina abstracción	83
Creciente uso del documento escrito	83
La labor de los juristas clásicos	83
La producción escrita	84
Ius publice respondendi	84
Sabinianos y proculyanos	85
Períodos de la jurisprudencia clásica	85
La legislación	86
Leges publicae	86
Senadoconsultos	86
Constituciones imperiales	86
La labor jurisdiccional	87
El Edictum Perpetuum	87
Derecho posclásico	87
Caracteres	87

La costumbre	88
La jurisprudencia	89
Ley de citas	89
La legislación	90
El Código Teodosiano	90
Corpus iuris civilis	91
Interpretación del corpus	93
Modo de citar los pasajes del Corpus iuris	94

CAPITULO IV

VIGENCIA ULTERIOR DEL DERECHO ROMANO

El Derecho Romano en Oriente	95
La producción posjustiniana	95
La paráfrasis de Teófilo	95
Compilaciones bizantinas	95
El Derecho Romano en Occidente	96
El sistema de la personalidad de las leyes	96
El renacimiento del Derecho Romano	97
Glosadores	98
Comentaristas	99
Humanistas	99
La recepción del Derecho Romano	100
La tendencia codificadora y la escuela histórica	101
El Derecho Romano en la Argentina	101

CAPITULO V

LAS PERSONAS

Comienzo y fin de la existencia	105
Nacimiento	105
Muerte	106

El "status"	106
Status libertatis	107
Los esclavos	107
Los libres	112
Situaciones afines a la esclavitud	114
Status civitatis	116
(A) Los ciudadanos romanos	116
(B) Los latinos	118
(C) Los peregrinos	119
Status familiae	120
(A) Sui iuris	120
(B) Alieni iuris	120
Causas modificativas del "status"	120
(A) La edad	120
(B) El sexo	122
(C) El honor civil. La infamia	122
(D) Enfermedad mental	123
Personas jurídicas	123
El estado romano	124
El fisco	124
Municipios	125
Asociaciones	125
Requisitos y funcionamiento	125
Fundaciones	126

CAPITULO VI

LAS COSAS

Concepto de Cosa	129
Patrimonio	130
División de las cosas	131
División de las cosas según su condición jurídica fundamental	132

Res in commercio - Res extra commercium	132
Res in patrimonio - Res extra patrimonium	132
Res divini iuris - Res humani iuris	132
División de las cosas patrimoniales según concepciones o estructuras de la primitiva sociedad romana	135
Res mancipi - Res nec mancipi	135
Cosas muebles - Cosas inmuebles	135
División de las cosas según determinadas características o particularidades	136
Cosas consumibles - Cosas no consumibles	136
Cosas fungibles - Cosas no fungibles	136
Cosas divisibles - Cosas indivisibles	136
Cosas simples - Cosas compuestas - Universalidades de cosas	137
Partes de cosas - Cosas accesorias	137
Frutos	138

CAPÍTULO VII

EL NEGOCIO JURIDICO

Hechos y actos jurídicos	140
Actos y negocios jurídicos	141
Clasificaciones	142
Elementos del negocio jurídico	143
(A) Esenciales	143
(B) Naturales	146
(C) Accidentales	147
1) Condición	147
2) Plazo o término	151
3) Modo o cargo	152
Representación en los negocios jurídicos	153
Interpretación de los negocios jurídicos	155
Divergencia entre voluntad y declaración	158
Ineficacia del negocio jurídico	158